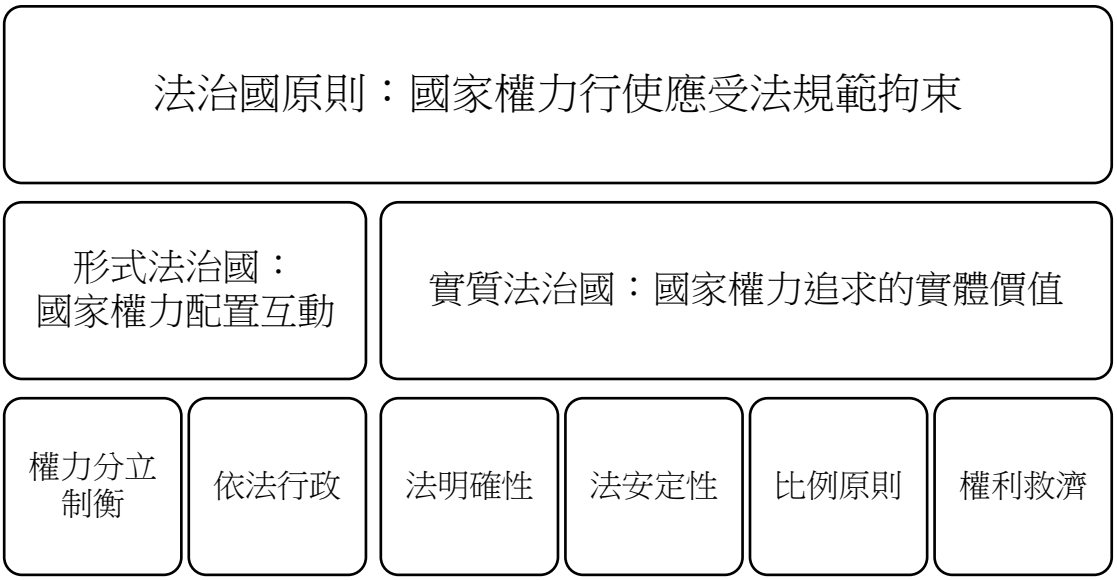
114 憲法期末課輔講義[*]

壹、 法治國原則.....2
一、 法治國原則體系概觀.....2
二、 依法行政原則.....2
（一） 法律優位.....2
（二） 法律保留.....2
三、 法律明確性原則.....5
四、 法律安定性原則.....7
（一） 溯及禁止原則.....8
（二） 信賴保護原則.....9
五、 比例原則.....11
貳、 基本權總論.....12
一、 基本權的規範定性.....12
二、 基本權的功能.....13
三、 基本權的權利主體.....17
四、 特別權力關係.....19
五、 基本權審查架構.....20
參、 人身自由.....22
一、 保障範圍.....22
二、 權利干預.....22
三、 干預的正當化.....23
肆、 隱私權.....28
一、 人格發展自由概論.....28
二、 保障範圍.....30
三、 權利干預.....31
四、 重要實務見解.....32
伍、 言論自由.....40
一、 保障範圍.....40
二、 權利干預.....42
三、 干預的正當化.....43
四、 重要實務見解.....46
陸、 平等權.....56
一、 保障範圍.....56
二、 權利干預.....58
三、 干預的正當化.....59

[*] 臺灣大學法研所公法組二年級康飛白編製，助教信箱：constitutionta@gmail.com

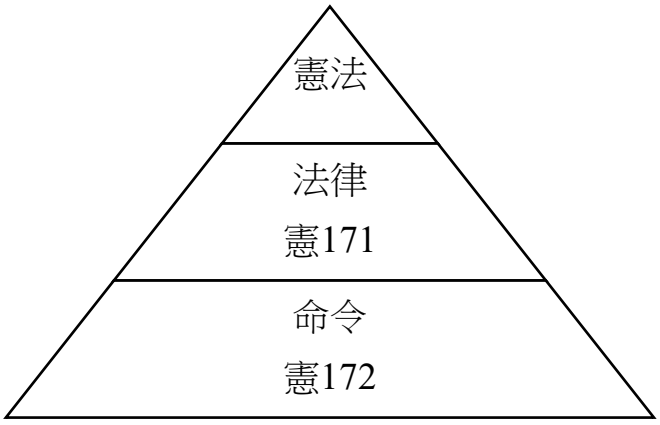
壹、 法治國原則

一、 法治國原則體系概觀



二、 依法行政原則

（一）法律優位



（二）法律保留

1. 意義：國家行為須有法律授權始得為之；無法律即無行政。
2. 原理：雙元民主制下為何仍須法律保留[1]？

[1] 法律保留最初源自君主立憲制的發展下制衡王權的需求，要求君王對人民自由及財產的干預須獲人民（國會）同意，但隨著王權式微，此一權利移轉至國會，而有「全部保留」之說。然而，國家權力全部集中於立法機關無異於另一種「集權」，亦有礙日常政務推行。參李建良，行政法

(1) 國會的民主正當性有多元、合議特質[2]→國會相對於獨任制的行政權較可能保持中立、不偏頗

(2) 法律普遍、抽象之本質→法律獨立、公正性有利權利保障

3. 階層化法律保留

(1) 原理：依影響基本權的程度決定規範密度要求（重要性理論）

(2) 體系

A. 憲法保留：憲法自為規範，法律*不得*限制。

B. 國會保留（絕對法律保留）：法律*應*直接規範。

a. 罪刑法定

b. 組織及程序法定（J793）

c. 租稅法定（J703）

C. 國會授權（相對法律保留）：法律*得委由*命令規定。

→**授權明確性原則**

D. 非屬法律保留：法律*得不*規範，由行政逕行決定。

E. 行政保留：法律*不得*限制，專由行政決定。

釋字第 443 號理由書第 1 段

憲法所定人民之自由及權利範圍甚廣，凡不妨害社會秩序公共利益者，均受保障。惟並非一切自由及權利均無分軒輊受憲法毫無差別之保障：**關於人民身體之自由，憲法第八條規定即較為詳盡，其中內容屬於憲法保留之事項者，縱令立法機關，亦不得制定法律加以限制**（參照本院釋字第三九二號解釋理由書），而憲法第七條、第九條至第十八條、第二十一條及第二十二條之各種自由及權利，則於符合憲法第二十三條之條件下，得以法律限制之。至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異：諸如**剝奪人民生命或限制人民身體自由者，必須遵守罪刑法定主義，以制定法律之方式為之**；涉及人民**其他自由權利之限制者，亦應由法律加以規定，如以法律授權主管機關發布**

基本十講，頁 292-293，2021 年。

[2] 許宗力，基本權利：第五講——基本權的保障與限制（上），月旦法學教室，11 期，頁 72：國會的組成具直接與多元的民主正當性基礎，議事程序又保有直接、透明、繁瑣、言詞辯論與多數決的特性，是由其擔當國家重要事項，包括嚴重影響基本權之保障的干預決定的做成，最符合國家機關最適功能配置原則的緣故。

命令為補充規定時，其授權應符合具體明確之原則；若僅屬與**執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範**，雖因而對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許。又關於**給付行政措施，其受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，倘涉及公共利益之重大事項者，應有法律或法律授權之命令為依據之必要**，乃屬當然[3]。

釋字第 522 號理由書第 1 段

立法機關得以委任立法之方式，授權行政機關發布命令，以為法律之補充，雖為憲法之所許，惟其**授權之目的、內容及範圍應具體明確**，始符憲法第二十三條之意旨，迭經本院解釋在案。至於**授權條款之明確程度，則應與所授權訂定之法規命令對人民權利之影響相稱**。刑罰法規關係人民生命、自由及財產權益至鉅，自應依循罪刑法定主義，以制定法律之方式為之，如法律授權主管機關發布命令為補充規定時，**須自授權之法律規定中得預見其行為之可罰，方符刑罰明確性原則**。

釋字第 604 號許宗力大法官協同意見書

釋字第五二二號解釋涉及的是刑罰法規之授權，因刑罰制裁影響人民權利至鉅，故其授權是否符合授權明確之要求，自當為最嚴格之審查。在嚴格審查之下，該號解釋即要求刑罰之構成要件，原則上應由法律定之，若法律就其構成要件，授權以命令為補充規定者，其授權之目的、內容及範圍應具體明確，而自授權之法律規定中得預見其行為之可罰，方符授權明確之要求，如必須從行政機 關所訂定之行政命令中，始能確知可罰行為內容之情形者，即與授權明確之意旨不符。據此，**倘採嚴格審查標準，要符合授權明確之要求，原則上似應具備三項要件：首先，授權之目的、內容及範圍三者皆應分別明確規定；其次，授權之目的、內容及範圍必須明示於授權之法律規定本身，亦即授權條款本身；最後，授權之規定須達到使人民「自授權之法律規定中得預見其行為之可罰」之明確程度。**

若以釋字第五二二號解釋所建立之嚴格審查標準為基準，則在**較寬鬆之審查**下，應無須嚴格要求立法者須自行於授權條款本身，分別就授權之目的、內容與範圍一一作明確之規定。 毋寧，**即使授權之內容與範圍未明示於法律條文，只要授權目的明確即為已足，因原則上並不難經由解釋，從授權之目的推論出授權之內容與範圍……且授權之目的是否明確，亦不以授權之目的具體明示於**

[3] 釋字第 614 號理由書第 1 段：「給付行政措施如未限制人民之自由權利，固尚難謂與憲法第二十三條規定之限制基本權利之法律保留原則有違，惟如涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，原則上仍應有法律或法律明確之授權為依據，主管機關始得據以訂定法規命令。」

授權條款本身為必要，只要能依一般法律解釋方法，從授權條款所依附之法律的整體，特別是從相關法條文義、法律整體之體系關連與立法目的，可推知授權之目的為何，亦為已足。此外，授權之規定也無須達到使人民「自授權之法律規定中得預見其行為之可罰」之明確程度，只要達到讓行政機關知悉其在訂定命令時所應遵循之方針與原則即可。

三、 法律明確性原則

（一）規範目的：避免國家恣意執法、使受規範者預見行為的法律後果

（二）法律的抽象、普遍性 ≒ 現實複雜、變遷

1. 構成要件：不確定法律概念、概括條款
2. 法律效果：裁量
3. 審查標準：基本權重要程度與侵害程度、事物領域、規範對象

（三）具體判準[4]

1. 文義可理解
2. 受規範者可預見
3. 司法可審查確認

釋字第 432 號理由書第 1、2 段

法律明確性之要求，非僅指法律文義具體詳盡之體例而言，立法者於立法定制時，仍得**衡酌法律所規範生活事實之複雜性及適用於個案之妥當性，從立法上適當運用不確定法律概念或概括條款**而為相應之規定。有關專門職業人員行為準則及懲戒之立法使用抽象概念者，苟其**意義非難以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認**，即不得謂與前揭原則相違。

會計師法第三十九條規定會計師應付懲戒之各種事由，其中第六款「其他違反本法規定者」，既限於會計師法所定義務，其範圍應屬可得確定，符合法律明確性原則。同法第十七條規定：「會計師不得對於指定或委託事件，有不正當行為或違反或廢弛其業務上應盡之義務」，其目的在確立會計師之行為標準及注意義務，其中「廢弛其業務上應盡之義務」，係指應為而不為，及所為未達會計師應有之水準而言。此項規定一方面基於**會計師之職業義務無從窮舉之考**

[4] 此與「授權之目的、內容及範圍應具體明確」的授權明確性原則應予區分，後者是在法律保留原則之下，要求國會對特定事項若不自為規範，至少其授權規範應具體明確，不可概括授權於行政部門。

量；一方面則鑒於會計師為經國家考試及格始得執行業務之專門職業人員，於其執行業務時何種作為或不作為構成業務上應盡義務之違反或廢弛，足以損及當事人之權益暨大眾之交易安全，可**憑其專業知識予以判斷**，並非難以理解，對於懲戒權之發動亦非不能預見，縱其內容及範圍具有某程度之不確定性或概括性，惟個案事實是否屬該規定所欲規範之對象，仍可經由司法程序依照社會上客觀價值、職業倫理等，按具體情況加以認定及判斷，要無礙於法安定性之要求。會計師法第十七條對於會計師職業義務之規定，第三十九條對違反此項注意義務之懲戒規定，係為維持會計師專業水準，增進公共利益而採取之必要措施，符合首開意旨，與憲法第十五條工作權之保障尚無違背。

釋字第 636 號理由書第 1、3、5 段

基於法治國原則，以法律限制人民權利，其構成要件應符合法律明確性原則，**使受規範者可能預見其行為之法律效果，以確保法律預先告知之功能，並使執法之準據明確，以保障規範目的之實現**。依本院歷來解釋，法律規定所使用之概念，其意義依法條文義及立法目的，如非受規範者難以理解，並可經由司法審查加以確認，即與法律明確性原則無違（本院釋字第四三二號、第四九一號、第五二一號、第五九四號、第六０二號、第六一七號及第六二三號解釋參照）。又依前開憲法第八條之規定，國家公權力對**人民身體自由之限制**，於一定限度內，既為憲法保留之範圍，若涉及嚴重拘束人民身體自由而與刑罰無異之法律規定，其法定要件是否符合法律明確性原則，自應受**較為嚴格之審查**。

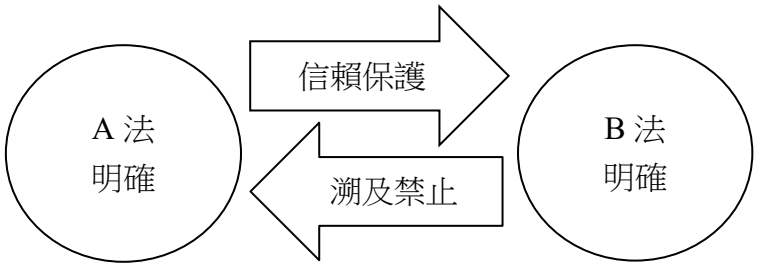
本條例第二條明文規定**流氓**之定義，其中第三款所謂**霸佔地盤、敲詐勒索、強迫買賣、白吃白喝、要挾滋事及為其幕後操縱**，係針對流氓行為之描述。依據**一般人民日常生活與語言經驗**，以及**司法審查之實務**，敲詐勒索與強迫買賣，足以理解為對被害人施以詐術、恐嚇、強暴、脅迫等行為，誤導或壓制被害人自由意志，而使被害人交付財物或完成一定之買賣行為；幕後操縱，則足以理解為對他人行為意思之形成、行為之決定與行為之實施為實質上之支配。上開構成要件行為之內涵，均為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，俱與法律明確性原則尚無違背。

本條例第二條第三款規定之**欺壓善良**、第五款規定之**品行惡劣、遊蕩無賴**均屬對個人社會危險性之描述，其所涵攝之行為類型過於空泛，**非一般人民依其日常生活及語言經驗所能預見，亦非司法審查所能確認**，實務上常須與強暴、脅迫、恐嚇等行為或與同條文其他各款規定合併適用。此基本構成要件所涵攝之行為內容既不明確，雖第五款另規定「有事實足認為有破壞社會秩序或危害他人生命、身體、自由、財產之習慣」，亦不能使整體構成要件適用之範圍具體明確，因此上開欺壓善良及品行惡劣、遊蕩無賴之規定，與法律明確性原則不符。

釋字第 767 號理由書第 5 段

系爭規定所謂「**常見且可預期之藥物不良反應**」，係屬不確定法律概念。「常見」、「可預期」之意義，依據一般人民日常生活與語言經驗，尚非難以理解，而藥物「不良反應」於藥害救濟法第 3 條第 4 款亦已有明確定義。**又一般受規範者（即病人及其家屬）依系爭規定縱無法完全確知其用藥行為是否符合請求藥害救濟之要件，惟應可合理期待其透過醫師之告知義務**（即醫療機構、醫師於診治病人時，應向病人或其家屬等告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及藥物可能之不良反應等，醫療法第 81 條、醫師法第 12 條之 1 參照）、**藥袋上標示或藥物仿單上記載**，就用藥之不良反應之可預期性、發生機會及請求藥害救濟之可能性等，可以有合理程度之預見。另常見、可預期之意義，主管機關參照國際歸類定義，將不良反應發生率大於或等於百分之一者，定義為系爭規定所稱之「常見」（改制前行政院衛生署 100 年 10 月 7 日署授食字第 1001404505 號函參照）；且前揭標準業經藥害救濟法第 15 條所定之藥害救濟審議委員會所援用，於**實務上已累積諸多案例可供參考**。是其意義於個案中並**非不能經由適當組成之機構依其專業知識加以認定及判斷**[5]，且最終可由司法審查予以確認。綜上，系爭規定與法律明確性原則尚無不合。

四、 法律安定性原則



- 法律明確性：單一法律中的權利義務關係穩定
- 法律安定性：新舊法律間的權義關係穩定→人民對國家法秩序穩定存續的預見與信賴，在此基礎上規劃自己的行為與生活（法律不應突襲人民）

[5] 有見解主張法律明確性原則之審查亦應區別類型而適用不同審查標準，如刑法領域基於罪刑明確原則應從嚴，涉及公法上給付請求權之創設及經驗上難以完全確定的科技風險則可從寬。從而釋憲實務若以各該專業機構的知識能力為準，而非僅以一般人民的理解能力為準，來認定法律文義是否可理解、可預期，即是從寬審查法律明確性原則的展現。參釋字第 767 號黃昭元大法官協同意見書。

（一）溯及禁止原則

1. 真正溯及既往（釋 525、793；112 憲判 3）：信賴利益→原則禁止，例外容許

2. 不真正溯及既往（釋 620、717、781-783；111 憲判 18）：典範變遷→原則許可，例外禁止（需討論信賴保護）

真正或不真正溯及既往的判斷，其實就是分辨溯及既往或「實非」溯及既往。判斷上，首應觀察法律生效時點，判別其究係「向後」或「向前」生效，前者指舊法如同被新法「抽換取代」，從而「塞給」過去的事實一個**當初不存在**的新規範；後者則指舊法為新法所「接續銜接」，縱使新法對已發生的事實或法律地位有所影響，其仍是「向將來地」發生規範效力，而非溯及地規範過去的事實[6]。

釋字第 717 號理由書第 4 段

按**新訂之法規，原則上不得適用於該法規生效前業已終結之事實或法律關係**，是謂禁止法律溯及既往原則。倘新法規所規範之法律關係，跨越新、舊法規施行時期，而構成要件事實於新法規生效施行後始完全實現者，除法規別有規定外，應適用新法規（本院釋字第六二0號解釋參照）。此種情形，係將**新法規適用於舊法規施行時期內已發生，且於新法規施行後繼續存在之事實或法律關係，並非新法規之溯及適用**，故縱有減損規範對象既存之有利法律地位或可得預期之利益，無涉禁止法律溯及既往原則。系爭規定以退休公教人員每月退休所得不得超過依最後在職同等級或同薪級人員現職待遇計算之退休所得一定百分比之方式，對公保養老給付金額優惠存款設有上限，使其原得以優惠利率存款之金額，於系爭規定發布施行後減少，致其退休後之優惠存款利息所得顯有降低；同時亦減損在職公教人員於系爭規定生效前原可得預期之相同利益。惟**系爭規定僅係適用於其生效後國家與退休公教人員、在職公教人員之間仍繼續存在之法律關係，並非溯及適用於系爭規定生效前業已終結之事實或法律關係**。況且退休公教人員依據系爭要點辦理優惠存款，係以定期簽約方式辦理，

[6] 李建良，法律的溯及既往與信賴保護原則，台灣本土法學雜誌，24 期，頁 82，2001 年。

對於已簽約而期限未屆至之部分，並未一體適用系爭規定。核諸上開說明，系爭規定之適用，尚無涉禁止法律溯及既往原則。
111 年憲判字第 18 號理由第 69 段 **沒收新制**並非針對行為人破壞法益之違法行為本身而設，而係為終止該行為所生之不法財產秩序。又，犯罪所得之產生雖係基於違法行為，然無論該違法行為是否終止、何時終止，亦不論行為人是否構成犯罪，**自犯罪所得產生之時起，不法財產秩序已然形成，且仍繼續存在至該犯罪所得被剝奪時為止**。因此，系爭規定，雖導致刑法第 38 條之 1 第 1 項、第 2 項沒收犯罪所得之規定，適用於該條施行前已發生之犯罪所得，然因該不法財產秩序，於該條規定施行後，仍繼續存在，故系爭規定**屬不真正溯及既往之法規範，而無違法律不溯及既往原則**。
112 年憲判字第 3 號理由第 72、73 段 國家與支領**退離給與**之退休（職、伍）公職人員間，雖存在繼續性法律關係，惟系爭規定二係具有確認採計社團專職人員年資部分為違法之意旨，而**其法律效果係直接以重新核計之結果，取代退休（職、伍）公職人員於退休（職、伍）時原核計之年資及退離給與**，並從而發生系爭規定三所定返還「溢領退離給與」之情事。是系爭規定二，及系爭規定三其中關於政務人員部分，**核屬真正溯及之法規範**。 惟如前所述系爭條例係為落實**轉型正義**，其目的在於確立及深化自由民主憲政秩序價值，避免國家再次重蹈黨國威權體制之覆轍，具有**特別重要之公共利益**（本判決理由第 62 段參照）。是系爭規定二及系爭規定三關於政務人員部分，雖為真正溯及性之法規範，然**仍非憲法所當然不許**。

（二）信賴保護原則

1. 功能：情事或典範變遷下，調節公益追求與信賴利益保護

2. 審查流程

   (1) 信賴基礎：如法規存在客觀施行期間，人民得預見，則根本不生信賴。

   (2) 信賴表現：當事人僅是主觀願望期待而無客觀信賴行為，則欠缺信賴表現。

   (3) 信賴瑕疵：原法規重大明顯違反上位規範（客觀），或是基於當事人不正手段而發布（主觀），則信賴不值得保護。

   (4) 保護方式：若通過信賴保護要件，對信賴利益之限縮應注意比例原則，

如採取過渡條款、補救措施等配套緩衝。

釋字第 717 號理由書第 1、2 段

信賴保護原則涉及法秩序安定與國家行為可預期性，屬法治國原理重要內涵，其作用非僅在保障人民權益，更寓有藉以實現公益之目的。人民對**依法規而取得之有利法律地位或可合理預期取得之利益，於客觀上有表現其信賴之事實，而非純為願望或期待，並具有值得保護之價值者**（本院釋字第五二五號解釋參照），其信賴之利益即應加以保護。法規變動（制定、修正或廢止）時，在無涉禁止法律溯及既往原則之情形，對於人民既存之有利法律地位（本院釋字第五二九號解釋參照）或可得預期之利益（本院釋字第六０五號解釋參照），國家除因有憲政制度之特殊考量外（本院釋字第五八九號解釋參照），原則上固有決定是否予以維持以及如何維持之形成空間，惟仍應注意人民對於舊法有無值得保護之信賴及是否符合比例原則。

授予人民經濟利益之法規預先定有施行期間者，在該期間內即應予較高程度之信賴保護，非有極為重要之公益，不得加以限制；若於期間屆滿後發布新規定，則不生信賴保護之問題。其未定有施行期間者，如客觀上可使規範對象預期將繼續施行，並通常可據為生活或經營之安排，且其信賴值得保護時，須基於公益之必要始得變動。**凡因公益之必要而變動法規者，仍應與規範對象應受保護之信賴利益相權衡，除應避免將全部給付逕予終止外，於審酌減少給付程度時，並應考量是否分階段實施及規範對象承受能力之差異，俾避免其可得預期之利益遭受過度之減損**。

111 年憲判字第 18 號理由第 70、71 段

又人類生活有其連續性，新法雖無溯及效力，對人民依舊法所建立之生活秩序，仍難免發生影響。是法律之變動在無涉真正溯及既往之情形，依憲法信賴保護原則，仍應進一步考量人民是否具有值得保護之正當合理信賴；於信賴值得保護之情形，尚應就公益與信賴利益間為衡量，俾符憲法信賴保護原則之意旨（司法院釋字第 574 號及第 717 號解釋參照）。

查刑法中所定各該犯罪行為之構成要件，係立法者認其行為具反社會性，應以刑罰此一強烈之手段予以制裁。行為該當構成要件且具不法性者，自始即為法秩序所不許，依此取得之犯罪所得亦隨之沾染不法，該不法之特性並不因行為時有無沒收犯罪所得之規定，而有差異。換言之，沒收因違法行為所獲得而持續帶有污點之犯罪所得，其背後所彰顯之普世價值，係宣示自始即不保護不正權利之取得及保有。是，**新法雖影響犯罪行為人及非善意之第三人依舊法所建立之生活秩序，然因犯罪所得係透過破壞原有法秩序之違法行為而取得，該財產自始存有沾染不法之重大瑕疵，犯罪行為人及非善意第三人信賴其得依舊法**

永久保有犯罪所得，自不值得保護。

釋字第 793 號理由書第 61 段

有系爭規定五後段規定之適用之法人、團體或機構等組織，於其曾受政黨實質控制，但於黨產條例施行前即已脫離其控制之時，就系爭規定五後段規定將其溯及納為規範對象，縱欠缺預見可能性，然其據以信賴之基礎，係源自戒嚴與動員戡亂之非常時期下黨國不分之威權體制，**與自由民主憲政秩序大有扞格**，**其信賴自不值得保護**，不生信賴保護之問題。是系爭規定五後段規定，與法律不溯及既往原則尚屬無違。

112 年憲判字第 3 號理由第 74 段

況考試院於 58 年至 72 年間發布採計社團專職人員年資之函令或年資互相採計要點，具有**明顯違反上位規範之重大瑕疵**（本判決理由第 46 段參照），依該函令或要點而取得退離給與之社團專職人員，**並無值得保護之信賴**（司法院釋字第 525 號解釋理由書第 2 段參照）。

五、 比例原則

（一）意義：劃分基本權之「限制／干預」與「侵害」。唯有當國家權力行使，無論在保護法益之選擇或限制手段之採用都受到憲法拘束，始得謂基本權受憲法保障[7]。

（二）內涵

1. 適當：手段適合達成目的（合目的性）
2. 必要：在多種適當手段之中，選擇對人民權利侵害最小的手段
3. 衡平（狹義比例原則）[8]：必要手段所造成的權利侵害（成本）不得高過達成的目的（利益）

釋字第 699 號理由書第 3-5 段

立法者為加強道路交通管理，維護交通秩序，確保交通安全之目的，制定道路

[7] 參許宗力，基本權利：第六講——基本權的保障與限制（下），月旦法學教室，14 期，頁 50。
[8] 許宗力，註 7，頁 8：因通常對基本權侵犯越嚴重，對目的之達成越為有效，致吾人確實難以找到一個對基本權限制較輕微，但對目的之達成卻仍同樣「特別有效」的可能比較手段來。在此技窮之時，就可以清楚凸顯出狹義比例原則的存在意義來，因本例（按：以死刑禁止賭博）立法者所追求公益的份量明顯無法正當化其對基本權造成的嚴重侵犯，亦即目的與手段明顯不合比例，故援用狹義比例原則，即能達到排除該明顯荒謬之手段的最終目的。

交通管理處罰條例(同條例第一條規定參照；下稱系爭條例)。有鑒於酒後駕車系爭規定（按：道路交通管理處罰條例）……係為考量道路交通行車安全，保護大眾權益，其**目的洵屬正當**，且所採吊銷駕駛執照等手段，亦可促使駕駛人接受酒測，進而遏止酒後駕車之不當行為，防範發生交通事故，**有助於上開目的之達成**。

依內政部警政署八十八年至九十年間之統計數字卻顯示，酒後駕車肇事傷亡事件有逐年上升之趨勢。鑒於汽車駕駛人拒絕接受酒測，或係為逃避其酒後駕車致可能受刑法第一百八十五條之三公共危險罪之處罰。立法者遂……提高拒絕酒測之罰責，以防堵酒駕管制之漏洞，有效遏阻酒後駕車行為。系爭規定所採手段，具有杜絕此種僥倖心理，促使汽車駕駛人接受酒測之效果，且**尚乏可達成相同效果之較溫和手段**，自應認系爭規定係達成前述立法目的之必要手段。

系爭規定之處罰，固限制駕駛執照持有人受憲法保障之行動自由，惟駕駛人本有依法配合酒測之義務，且由於酒後駕駛，不只危及他人及自己之生命、身體、健康、財產，亦妨害公共安全及交通秩序，是其**所限制與所保護之法益間，尚非顯失均衡**。

貳、 基本權總論

一、 基本權的規範定性

【權利 vs 義務】：權利的另一面是義務，有權利即有義務。然而，有義務不一定即有權利，國家違反義務（違法違憲）不表示人民此時即可請求救濟。換言之，義務的範圍大於權利，義務超出權利的部分為「反射利益」。

（一） 主觀公權利

1. 作為人民向國家請求的基礎
2. 個人權利受侵害→具體權利救濟：裁判／規範憲法審查

（二） 客觀法秩序

1. 作為拘束國家的價值規範
2. 國家違反義務（≠個人司法救濟）[9]→抽象規範審查：機關聲請、法官聲

[9] 這個區分來自德文基本權利 Grundrecht 中的權利 Recht 一詞兼有「權利」和「法」的意思，因此當提到 Recht，尚須區分是指可以請求的主觀權利，或不能請求、單純課予國家義務的客觀的法。但中文的「權利」沒有這兩層意涵，故既謂「基本權」，其中又有「純屬國家義務而無權利

請、少數立委聲請

二、 基本權的功能

（一） 防禦權（主觀＋消極）→法治國原則

1. 最基本、所有基本權均有
2. 請求不干預：事前防止、事後排除
3. 禁止過度干預：比例原則
4. 問題：保障「巴黎橋下睡覺的自由」

（二） 給付請求權（主觀＋積極）→社會國原則

1. 有形物、無形服務[10]→給付不足禁止：符合**人性尊嚴的最低需求**

> 釋字第 766 號理由書第 3 段
>
> **國民年金保險**係國家為實現人民享有**人性尊嚴之生活**，依憲法第 155 條及憲法增修條文第 10 條第 8 項實施社會保險制度之基本國策而建立之社會福利措施，為**社會保險**之一種（立法院公報第 96 卷第 58 期第 132 頁及第 135 頁參照）。國民年金法即係依上開憲法意旨而制定之法律，旨在「確保未能於相關社會保險獲得適足保障之國民於老年、生育及發生身心障礙時之基本經濟安全，並謀其遺屬生活之安定。」（國民年金法第 1 條參照）國民年金法第 40 條第 1 項規定：「被保險人死亡者、符合第 29 條規定而未及請領老年年金給付前死亡者，或領取身心障礙或老年年金給付者死亡時，遺有配偶、子女、父母、祖父母、孫子女或兄弟、姊妹者，其遺屬得請領**遺屬年金給付**。」遺屬年金係被保險人死亡事故發生時之主要保險給付，目的在謀求遺屬生活之安定，故被保險人之遺屬作為遺屬年金之受益人依法享有之遺屬年金給付請求權，屬社會保險給付請求權，具有財產上價值，應受憲法**財產權**之保障。且得請領遺屬年金之遺屬，或為未成年人，或為無謀生能力者，或為每月工作收入未超過其領取遺屬年金給付時之月投保金額者等（國民年金法第 40 條第 2 項參照），其等常因被保險人死亡頓失依怙而陷難以維持**最低生活需求**，因此遺屬年金之給付亦涉及被保險人遺屬受憲法第 15 條保障之**生存權**。綜上，立法者就兼受財產權與生存

性質」的部分，毋寧自相矛盾，許宗力老師即因而認為國家保護義務必然對應人民的保護請求權。參許宗力，基本權利：第二講——基本權的功能，月旦法學教室，2 期，頁 76。不過，「義務＞權利」的想法在行政法會持續扮演核心觀念，此處不妨理解為，基本權的客觀法秩序意指基本權的「價值、精神」必須貫徹所有國家權力行使即可。

[10] 又稱「受益權」功能，傳統上以受教育權或生存權、工作權等「社會權」為代表例。

權保障之遺屬年金給付請求權之限制，應符合憲法第 23 條比例原則之規定，並受**較為嚴格之審查**。亦即，其目的須為追求重要公益，所採手段與目的之達成間須具有實質關聯。

2. 組織、程序、法律、制度→給付不足禁止：權利有效行使仰賴國家作為[11]→制定**保護規範**

釋字第 709 號理由書第 4 段

憲法上正當法律程序原則之內涵，應視所涉基本權之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序之成本等因素綜合考量，由立法者制定相應之法定程序（本院釋字第六八九號解釋參照）。都市更新之實施，不僅攸關重要公益之達成，且嚴重影響眾多更新單元及其週邊土地、建築物所有權人之**財產權及居住自由**，並因其利害關係複雜，容易產生紛爭。為使主管機關於核准都市更新事業概要、核定都市更新事業計畫時，能確實符合重要公益、比例原則及相關法律規定之要求，並促使人民積極參與，建立共識，以提高其接受度，本條例除應規定主管機關應設置**公平、專業及多元之適當組織以行審議**外，並應按主管機關之審查事項、處分之內容與效力、權利限制程度等之不同，規定應踐行之**正當行政程序，包括應規定確保利害關係人知悉相關資訊之可能性，及許其適時向主管機關以言詞或書面陳述意見**，以主張或維護其權利。而於都市更新事業計畫之核定，限制人民財產權及居住自由尤其直接、嚴重，本條例並應規定由主管機關以**公開方式舉辦聽證**，使利害關係人得到場以言詞為意見之陳述及論辯後，斟酌全部聽證紀錄，說明採納及不採納之理由作成核定，始無違於憲法保障人民財產權及居住自由之意旨。

釋字第 748 號理由書第 13、16 段

適婚人民而無配偶者，本有**結婚自由**，包含「是否結婚」暨「與何人結婚」之自由（本院釋字第 362 號解釋參照）。該項自主決定攸關人格健全發展與人性尊嚴之維護，為重要之基本權（a fundamental right），應受憲法第 22 條之保障。按相同性別二人為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，既不影響不同性別二人適用婚姻章第 1 節至第 5 節有關訂婚、結婚、婚姻普通效力、財產制及離婚等規定，亦未改變既有異性婚姻所建構之社會秩序；且相同性別二人之婚姻自由，經法律正式承認後，更可與異性婚姻共同成為穩定社會之磐石。復鑑於婚姻自由，攸關人格健全發展與人性尊嚴之維護，就成立上述親密、排他之永久結合

[11] 傳統上認為具組織及程序保障功能的基本權如廣播電視自由、訴訟權、學術自由等。

之需求、能力、意願、渴望等生理與心理因素而言，其不可或缺性，於同性性傾向者與異性性傾向者間並無二致，均應受憲法第 22 條婚姻自由之保障。現行婚姻章規定，未使**相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係**，顯屬立法上之重大瑕疵。於此範圍內，與憲法第 22 條保障人民婚姻自由之意旨有違。

究國家立法規範異性婚姻之事實，而形成**婚姻制度**，其考量因素或有多端。如認婚姻係以保障繁衍後代之功能為考量，其著眼固非無據。然查婚姻章並未規定異性二人結婚須以具有生育能力為要件；亦未規定結婚後不能生育或未生育為婚姻無效、得撤銷或裁判離婚之事由，是**繁衍後代顯非婚姻不可或缺之要素**。相同性別二人間不能自然生育子女之事實，與不同性別二人間客觀上不能生育或主觀上不為生育之結果相同。故以不能繁衍後代為由，未使相同性別二人得以結婚，顯非合理之差別待遇。倘以婚姻係為維護基本倫理秩序，如結婚年齡、單一配偶、近親禁婚、忠貞義務及扶養義務等為考量，其計慮固屬正當。惟若容許相同性別二人得依婚姻章實質與形式要件規定，成立法律上婚姻關係，且要求其亦應遵守婚姻關係存續中及終止後之雙方權利義務規定，並**不影響現行異性婚姻制度所建構之基本倫理秩序**。是以維護基本倫理秩序為由，未使相同性別二人得以結婚，顯亦非合理之差別待遇。凡此均與憲法第 7 條保障平等權之意旨不符。

3. 問題：涉及有限國家資源的分配利用，屬於立法者政策決定

（三） 參與請求權（主觀＋積極）→民主國原則

1. 直接民主：公投、選舉、被選舉
2. 間接民主：立法程序、行政程序

112 年憲判字第 11 號理由第 60 段

選舉乃多數人民透過集中意志，決定民意代表或各級政府首長之行為，人民參政權為民主政治與專制政治最關鍵之不同處，選舉尤為人民參政權中最核心之權利，透過人民選舉賦予民意代表或各級政府首長行使國家權力之正當性。我國憲法第 1 條明定民主共和國原則，第 2 條明定國民主權原則，係採民主政治體制。是**憲法第 17 條所保障之選舉權，乃民主國家中人民最基本之政治參與權利之一，其保障符合法定資格之選舉人，均得於公平、公正、公開之選舉中參與投票，選出回應多數民意之各種民選公職人員**，以具體實現憲法第 1 條及第 2 條所揭示之民主原則。**選舉制度之設計固屬立法形成之自由，惟不得違背民主原則及憲法第 129 條至第 132 條之規定意旨**，自屬當然。

（四） 國家保護義務（客觀）

1. 意義：國家負有採取一定措施的義務，以保護人民基本權免於來自第三人的侵害。

2. 理論基礎：根據古典社會契約論，原處於自然狀態的人們自願放棄武力並組成國家，國家自應為人民提供保護，否則無以正當化自力救濟之禁止及國家對武力之獨占。

> 釋字第 445 號理由書第 7 段
>
> 集會自由以集體方式表達意見，為人民與政府間溝通之一種方式。人民經由此方式，主動提供意見於政府，參與國家意思之形成或影響政策之制定。從而國家在消極方面應保障人民有此自由而不予干預；**積極方面應提供適當集會場所，並保護集會、遊行之安全，使其得以順利進行**。

3. 國家保護義務與基本權放射效力

(1) **基本權放射效力**：基本權的侵害也可能來自其他私人（第三人），但基於基本權之**對國家性**，基本權之義務主體僅限於國家，不可直接向第三人主張，此時應由國家藉由保護義務之履行調節**私人間的基本權衝突**。

   A. 保護義務→給付不足禁止

   B. 防禦權→干預過度禁止

(2) 國家保護義務的履行方式：基於憲法最高性及基本權之客觀價值秩序，所有國家權力行使均受基本權拘束。

   A. 立法：**保護規範**之制定

      a. 民法：侵權責任損害賠償

      b. 刑法：犯罪行為刑事處罰

   B. 司法：保護規範之適用

a. 公序良俗、誠實信用……（vs 私法自治）

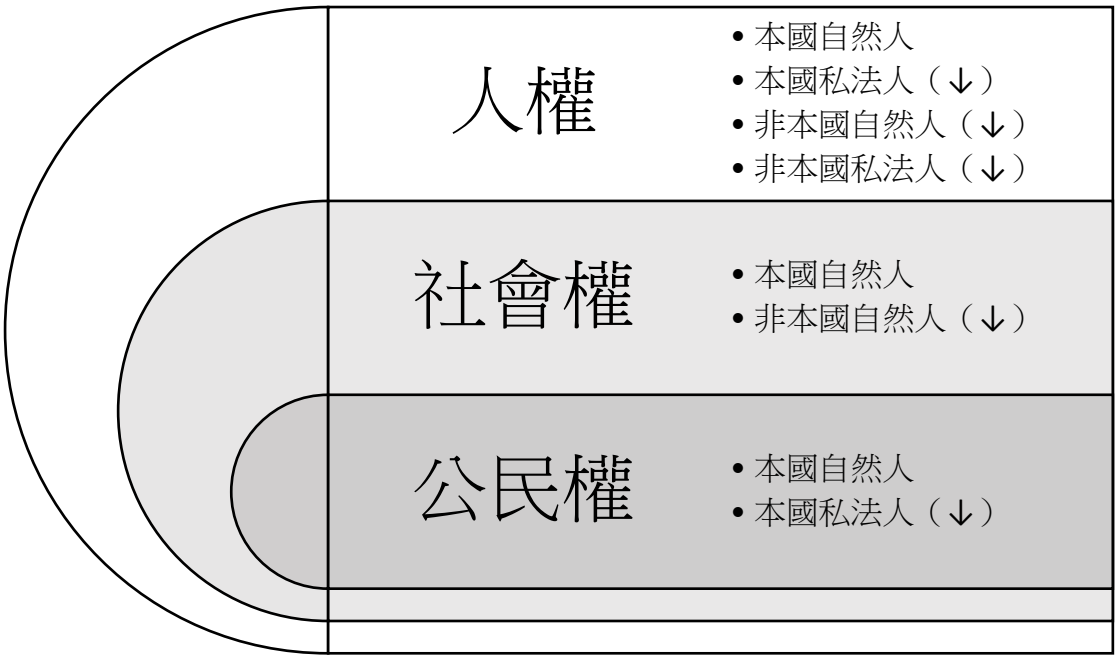
b. **憲法取向解釋**

111 年憲判字第 2 號理由第 11 段

民法第 195 條第 1 項前段規定……所稱「回復名譽之適當處分」……之範圍，除不得涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事外，亦應**依憲法保障人民言論自由之意旨，予以適度限縮**。是法院本應採行足以回復名譽，且**侵害較小**之適當處分方式，例如在合理範圍內由加害人負擔費用，刊載被害人判決勝訴之啟事或將判決書全部或一部刊載於大眾媒體等替代手段，而不得逕自採行侵害程度明顯更大之強制道歉手段。

4. 問題：國家保護義務的界限、風險社會的責任分配？

三、 基本權的權利主體



（一）集體權

111 年憲判字第 2 號理由第 11 段

維護人性尊嚴與尊重人格自由發展，乃自由民主憲政秩序之核心價值，人格權作為個人人格的基礎，乃為不可或缺之基本權利，而為憲法第 22 條所保障之基本人權之一，其中包括原住民身分認同權（本庭 111 年憲判字第 4 號判決參照）。另依憲法增修條文第 10 條第 11 項及第 12 項前段之規定，國家應

積極維護發展原住民族之語言及文化，並就其教育文化等事項予以適當之保障扶助。是由憲法第 22 條及憲法增修條文第 10 條第 11 項及第 12 項前段之規定整體觀察，**受憲法保障之原住民身分認同權，除保障個別原住民之身分認同外，亦包括各原住民族之集體身分認同**。

（二）大陸地區人民

憲法增修條文第十一條明文授權立法者得對「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理」為特別規定，解釋上包括對大陸地區人民關聯到臺灣的基本權利的特別規定，其前期乃是承認大陸地區人民，至少在與臺灣事務有關聯的基本權範圍內，享有我國憲法的基本權權利能力[12]。

釋字第 618 號理由書第 2、3 段

兩岸關係事務，涉及政治、經濟與社會等諸多因素之考量與判斷，對於代表多元民意及掌握充分資訊之立法機關就此所為之決定，如非具有明顯之重大瑕疵，職司法律違憲審查之**釋憲機關即宜予以尊重**。……基於原設籍大陸地區人民設籍臺灣地區未滿十年者，對自由民主憲政體制認識與其他臺灣地區人民容有差異，故對其擔任公務人員之資格與其他臺灣地區人民予以區別對待，亦屬合理，與憲法第七條之平等原則及憲法增修條文第十一條之意旨尚無違背。

（三）公法人？

111 年憲判字第 14 號理由第 59 段

按憲法為人民權利保障書，保障人民之權利乃憲法核心目的，為達此一目的，憲法乃賦與國家機關各種權限，並透過權力分立之設計，避免國家權力過度集中而可能侵害人民之權利。蓋人民所以有必要享有各種不同之基本權利，主要乃是因為作為人，得自由發展自己之人格，追求自己之利益之故，而作為**為人民服務之國家，本質上既不可能擁有如人民般得自由發展之人格，亦不可能如人民般享有得自由追求之私益，只能追求公益，以執行公共任務為職志，從而，國家自無受憲法第 15 條保障財產權之基本權利。公法人既為分擔國家任務而存在，其財產之取得，如本於公法人之地位而取得，自亦不受憲法第 15 條規定所保障。**

[12] 許宗力，基本權利：第三講——基本權主體，月旦法學教室，4 期，頁 82。許老師進而指出：即使承認大陸地區人民有基本權權利能力，並不就表示其實際享有的基本權地位能夠與我國人民所擁有者相提並論，毋寧，經兩岸關係條例根據增修條文第十一條之概括授權對其基本權特別限制的結果，其實質的基本權地位在許多方面甚至比外國人還不如。

（四）「國民權」[13]？

1. 公民權：基於國民主權原則，國家權力屬於國民全體，則參與形成國家權力或行使國家權力的權利，例如，選舉、罷免、創制與複決等參政權，以及服公職權等，唯限於本國人民始能擁有，不及於外國人。

2. 平等權：憲法第 7 條已明定「中華民國人民」，無解為包括外國人的餘地。

> 近期則有不同見解質疑以國民身分的他我之別作為憲法上權利主體的界線。理由在於，憲法本文及增修條文均有意區分「國民」及「人民」，其中未明確定義的「人民」概念本容有釋憲者形塑的空間。再者，國民主權原則不表示公民身分必須被用來排除任何「非公民」之憲法主體性，更不必然表示公民身分僅能等於由政治部門所定義之國籍；代表當下多數的立法機關不應向上定義憲法層次的「成員身分」。且國民主權強調統治者與被統治者的同一，既然不具國籍的在地外國居民仍為本國憲法效力所及，即不應將其排除在表彰統治權力之憲法以外。最後，公民身分的理論根源意在權力及權利的向外擴展及包含，而非對外限制或排除，國籍不應反而成為憲法權利之排除性要件[14]。

四、 特別權力關係

早期見解認為在軍隊、監獄、公務機關、學校等「特別生活領域」，於其「特別功能目的」所必要的範圍內，人民之基本權受一定程度限縮，並排除法律保留及司法救濟等法治國一般原則的適用。然而此等見解已為晚近釋憲實務所逐步揚棄。

> 釋字第 785 號理由書第 5、6 段
>
> **公務人員與國家間雖具有公法上職務關係，但其作為基本權主體之身分與一般人民並無不同**，本於憲法第 16 條**有權利即有救濟**之意旨，人民因其公務人員身分，與其服務機關或人事主管機關發生公法上爭議，認其權利遭受違法侵害，或有主張權利之必要，自得按相關措施與爭議之性質，依法提起相應之行政訴訟，並**不因其公務人員身分而異其公法上爭議之訴訟救濟途徑之保障**。……至是否違法侵害公務人員之權利，則仍須根據行政訴訟法或其他相關法律之規定，依個案具體判斷，尤應整體考量行政機關所採取措施之目的、性質以及干

[13] 許宗力，基本權利：第三講——基本權主體，月旦法學教室，4 期，頁 8。
[14] 范秀羽，從「我們的憲法」、「我們」到「我們的釋憲者」：形塑非國民之憲法上權利主體，臺大法學論叢，48 卷 1 期，1-19，2019 年。

預之程度，**如屬顯然輕微之干預，即難謂構成權利之侵害**。且行政法院就行政機關本於專業及對業務之熟知所為之判斷，應予以適度之尊重，自屬當然（本院釋字第 784 號解釋參照）。

五、 基本權審查架構

(一) 審查標的：國家行為 寫在開標及基本權干預即可

(二) 基本權干預

1. 基本權保障範圍

(1) 基本權內涵／要件

(2) 基本權主體 多數情況可省略

2. 基本權受限制／干預 涵攝

(三) 基本權干預的正當化[15] 涵攝

1. 形式合憲性：法律保留（及授權明確性）

2. 實體合憲性

(1) 法律明確性

(2) 法安定性

(3) 比例原則：目的－手段關聯

A. 審查標準

B. 目的正當

C. 手段適當、必要、衡平

■ 審查標準的選擇及用語[16]？

釋字 584 號許宗力大法官協同意見書

寬嚴不同的認定或者說審查標準。不同寬嚴審查標準的選擇，應考量許多因素，

[15] 這些層次的排列方式有時候還滿令人困惑的，甚至曾有國考答題要點稱「形式／實體合憲性」是不知所云的用語。總之最穩健的做法就是每個基本原則（法律保留、比例原則、法律明確、溯及既往禁止……）各開一標（「系爭規定違反／符合 XX 原則」），再進行審查並涵攝。

[16] 如同蘇老師所言，經過釋憲實務累積，臺灣已發展出臺派的審查體系，無需糾結於美派德派的審查標準用語歧異！

例如系爭法律所涉**事務領域**，根據**功能最適觀點**，由司法者或政治部門作決定，較能達到儘可能「正確」之境地，系爭法律**所涉基本權之種類、對基本權干預之強度，還有憲法本身揭示的價值秩序**等等，都會影響寬嚴不同審查基準之選擇。

112 年憲判字第 17 號許志雄大法官協同意見書

近年司法院解釋及憲法法庭判決於適用比例原則，為高密度審查時，除要求立法目的係為追求特別重要公共利益外，亦就適合性、必要性及比例性逐一詳加審查憲法法庭（112 年憲判字第 11 號判決參照）。然為中密度審查時，則要求目的須為追求重要公益，所採手段與目的之達成間須具有實質關聯，而未就適合性、必要性及比例性逐一審查（司法院釋字第 766 號解釋及憲法法庭 111 年憲判字第 9 號判決參照）實際上與實質關聯性基準無異。為低密度審查時，類皆表明目的如屬正當（追求公共利益），且其所採取之手段與目的之達成間具合理關聯，即與憲法第 23 條比例原則無違，同樣未就比例原則之三項內容審查（司法院釋字第 750 號、第 768 號、第 788 號與第 809 號解釋及憲法法庭 111 年憲判字第 19 號、112 年憲判字第 7 號與 112 年憲判字第 16 號判決參照），運作模式與合理性基準如出一轍。要之，以比例原則為**高密度審查時，尚維持比例原則之正規操作**；而為中密度或低密度審查時，業已變調，可謂**假比例原則之名，行美式中間審查基準（實質關聯性基準）或合理性基準之實**。

審查標準[17]	目的	手段
嚴格	特別重要公共利益	別無侵害較小之替代手段，手段與目的間具相稱性
中度	重要公共利益	手段與目的間具實質關聯
寬鬆	正當目的	手段與目的間具合理關聯

- 基本權競合：複數的基本權規範同時適用於同一事實、同一基本權主體
  - 特別／補充關係：僅需審查特別基本權

[17] 白話文：
- 嚴格＝推定違憲
- 中度＝不是嚴格也不是寬鬆
- 寬鬆＝說得通就行

- 想像競合：平行審查／合併審查[18]

參、 人身自由

一、 保障範圍

（一）權利主體：自然人

> 釋字 708 號理由書第 1 段
>
> 人身自由係基本人權，為人類一切自由、權利之根本，任何人不分國籍均應受保障，此為現代法治國家共同之準則。故我國憲法第八條關於人身自由之保障亦應及於外國人，使與本國人同受保障。

（二）權利客體：個人身體的行動自由→其他基本權的基礎

> 釋字第 699 號湯德宗大法官部分協同暨部分不同意見書
>
> 「行動自由」在我國憲法上的依據是第十條所稱「居住及遷徙之自由」，而其核心意涵則來自憲法第八條的「人身自由」。亦即，狹義的「人身自由」固指憲法第八條所規定的「人身安全」（即人民身體應有免於遭非法逮捕、拘禁、審問、處罰之自由）；**廣義的「人身自由」則以「人身安全」為基礎，擴及於憲法第十條所規定的「居住及遷徙之自由」，再擴及於「在不妨害社會秩序公共利益之前提下，人民依其意志作為或不作為之一般行為自由」（屬於憲法第二十二條所保障的概括基本權）**。三者的關係猶如同心圓般，乃由內（核心）而外（外沿），漸次開展。

二、 權利干預

（一） 人身自由的剝奪：於一定期間內拘束人民身體自由於特定處所（e.g.拘禁）→**憲 8**

[18] 不同自由權利發生想像競合的時候，原則上應該對所有受到限制的基本權進行合憲性審查，審查順序也沒有絕對的規則。只有在審查基準存在歧異的情況下，才有特別區辨審查依據的實益；在一般的情況下，會優先選擇與案例事實關聯性最強或保障程度最高的基本權去進行合憲性審查。若是自由權與平等權競合，則在審查客體涉及複數權利限制規範的不同構成要件，從而涉及**差別待遇的證成**時，應該以平等權進行審查；而當審查客體屬於**介入基本權利保障領域**，而會觸發基本權防禦權功能的高權干預行為，則應以自由權作為審查依據。蘇慧婕，剪不斷理還亂的表意人限制：評憲法法庭 112 年憲判字第 17 號判決，新學林法學，3 期，頁 58-59，2024 年。

釋字第 636 號理由書第 1 段

國家行使公權力限制人民身體自由，必須遵循法定程序，在一定限度內為憲法保留之範圍。所謂法定程序，依本院歷來之解釋，**凡拘束人民身體自由於特定處所，而與剝奪人民身體自由之刑罰無異者，不問其限制人民身體自由出於何種名義**，除須有法律之依據外，尚須分別踐行正當法律程序，且所踐行之程序，應與限制刑事被告人身自由所踐行之正當法律程序相類。

（二） 人身自由的限制：對人身實施短暫的立即直接強制手段（e.g.臨檢）→**憲 23、16**

三、 干預的正當化

（一） 形式要件：**憲法保留**、法律保留

（二） 實體要件：比例原則

1. 一罪不二罰（釋 775、799、812）

釋字第 799 號理由書第 23 段

按**對性犯罪者於刑罰執行完畢後，再施以強制治療**，旨在使具高再犯危險之性犯罪者，經由強制治療程序而降低其再犯危險，以保護社會大眾安全，並協助受治療者復歸社會。是強制治療本質上應為一種由專業人員主導實施之治療程序，受強制治療者係立於「病人」之地位接受治療，並以使受治療者有效降低其再犯危險為目的，而非對受治療者之刑事處罰。因此，強制治療制度之建構，自應以使受治療者得受有效治療，俾利日後重獲自由為核心指標，截然不同於犯罪之處罰。從而，強制治療制度之具體形成，包括規範強制治療之制度與其實際執行，無論涉及者為強制治療之治療處所（包含空間規劃及設施）、施以治療之程序、管理及專業人員之配置、參與等，整體觀察，**須與刑罰之執行有明顯區隔，始為憲法所許**。強制治療制度**如符合憲法明顯區隔之要求，即不生牴觸以犯罪之處罰為前提之罪刑法定或一事不二罰原則之問題**。

釋字第 812 號理由書第 22 段

我國刑事法採刑罰與**保安處分**雙軌之立法體制，立法者針對具有社會危險性之犯罪行為人，除就其犯罪行為依法處以刑罰外，另就其反社會人格或危險性格，施以各種保安處分，以期改善、矯治其偏差性格，維護社會大

眾之安全。換言之，保安處分並非針對犯罪行為人過去之犯罪行為所科處之刑罰，而是針對犯罪行為人之危險性，為預防其未來犯罪，危害社會大眾安全，所實施之矯治性措施，其與刑罰之憲法上依據及限制有本質性差異。從而，保安處分，尤其是拘束人身自由之保安處分，其制度之具體形成，包括規範設計及其實際執行，整體觀察，**須與刑罰有明顯區隔，始為憲法所許**（本院釋字第 799 號解釋參照）。

2. 罪刑相當（釋 775、777、112 憲判 3）

112 年憲判字第 17 號理由第 31 段

同為**販賣第一級毒品**者，其犯罪情節差異甚大……系爭規定基於防制毒品危害之立法目的，一律以無期徒刑為最低法定刑，而未依犯罪情節之輕重，提供符合個案差異之量刑模式，亦未對不法內涵極為輕微之案件設計減輕處罰之規定……對諸如無其他犯罪行為，且依其販賣行為態樣、數量、對價等，可認屬情節極為輕微，顯可憫恕之個案，縱適用刑法第 59 條規定酌減其刑，仍嫌情輕法重，致罪責與處罰不相當。於此範圍內，對人民受憲法第 8 條保障人身自由所為之限制，**不符憲法罪刑相當原則**，牴觸憲法第 23 條比例原則。

3. 正當法律程序[19]

(1) 憲 8 規範解析[20]

[19] 我國司法院大法官對於人身自由之剝奪計有兩種不同的程序模式要求：凡具刑事或其他處罰案件之原因事實背景者，大法官自釋字第 166 號解釋起，迄至最後出現的釋字第 664 號解釋止，始終盱衡憲法第 8 條的各項規定，堅持「法官保留」之要求。相反地，其若與刑事或其他處罰案件無涉者，相關的程序模式雖然發展較遲，但自釋字第 300 號解釋起，大法官卻也已歷經發現問題、指出差異、選擇路線等摸索的過程，逐漸形成另一套至釋字第 708 號及第 710 號解釋方所確立的程序模式，亦即：(一) 即時之司法救濟，並加上 (二) 人身自由之剝奪於逾越法定可剝奪之期間後，由法院審查決定續行與否。林明昕，論剝奪人身自由之正當法律程序：以「法官介入審查」機制為中心，臺大法學論叢，46 卷 1 期，頁 38-39，2016 年。林明昕老師認為，非刑事或其他處罰的人身自由剝奪只能「類推適用」憲法第 8 條程序規定，不能直接適用之，但基於該條的基本精神，立法者對此類人身自由剝奪的程序設計仍有一定界限，即以**即時有效的法官介入機制為最低要求**。

[20] 法官參與公權力剝奪人身自由之決定的模式，依據比較法觀察，至少有「法官保留」及「提審」等兩種最基本的類型。第一種模式，以德國為代表；但我國憲法第 8 條第 2 項第 1 句稱「人民…被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應…至遲於二十四小時內移送該管法院審問」，亦屬典型。這種模式，有關公權力對人身自由之剝奪的執行或續行與否，完全由法院決定；在此，雖然若干案件類型，因急迫或其他必要性，人民之身體自由得由公權力機關先行剝奪，惟該剝奪本身究屬暫時性質，其得否繼續進行，仍須由公權力機關移送法院為終局之決定。

相對於此，第二種類型的法官介入模式，亦即「提審」者，法官參與公權力剝奪人身自由之決定的程度則比較低。蓋在此一模式中，有關公權力對人身自由之剝奪的執行或續行與否，原則上僅由各公權力機關自行決定，法官不予置喙；然而針對該公權力機關的剝奪決定，人民得逕向法院請求保護，要求審查尚於進行中的人身自由之剝奪是否得以繼續，抑或立即終止。僅於此際，法

I 人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，**非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁**。非由法院依法定程序，不得審問處罰。非依法定程序之逮捕、拘禁、審問、處罰，得拒絕之。

II 人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應將逮捕拘禁原因，以書面告知本人及其本人指定之親友，並至遲於二十四小時內移送該管法院審問法官保留。本人或他人亦得聲請該管法院，於二十四小時內向逮捕之機關提審提審。

III 法院對於前項聲請，不得拒絕，並不得先令逮捕拘禁之機關查覆。逮捕拘禁之機關，對於法院之提審，不得拒絕或遲延。提審的補充規定

(2) 刑事或其他處罰（逮捕、拘禁、羈押、拘提、留置、管收）：法官保留／提審＋正當法律程序

釋字第 392 號理由書第 11 段 就剝奪人身之自由言，拘提與逮捕無殊，羈押與拘禁無異；且拘提與羈押亦僅目的、方法、時間之久暫有所不同而已，其他所謂「拘留」「收容」「留置」「管收」等亦無礙於其為「拘禁」之一種，當應就其實際剝奪人身（行動）自由之如何予以觀察，未可以辭害意。……**羈押**之將人自家庭、社會、職業生活中隔離，「拘禁」於看守所、長期拘束其行動，此人身自由之喪失，非特予其心理上造成嚴重打擊，對其名譽、信用—人格權之影響亦甚重大，係干預人身自由最大之強制處分，自僅能以之為「保全程序之最後手段」，允宜慎重從事，其非確已具備法定條件且認有必要者，當不可率然為之。是為貫徹此一理念，關於此一手段之合法、必要與否，基於人身自由之保障，**當以由獨立審判之機關**（按：狹義法院）**依法定程序予以審查決定，始能謂係符合憲法第八條第二項規定之旨意。**
釋字第 588 號理由書第 4 段 人身自由乃人民行使其憲法上各項自由權利所不可或缺之前提，憲法第八條第一項規定所稱「**法定程序**」，係指凡限制人民身體自由之處置，

院始行介入公權力剝奪人身自由的程序。以提審作為法官介入審查公權力剝奪人身自由之案件的模式，目前在比較法制上，似為多數立法例所採行；我國憲法第 8 條第 2 項第 2 句稱「本人或他人亦得聲請該管法院，於二十四小時內向逮捕之機關提審」，亦屬適例。此外，又由於我國憲法之前開條項第 1 句針對同一事項，另有法官保留的設計，因此在我國憲法中對於同一案件類型之人身自由剝奪的法官介入審查，明文兼具了法官保留與提審的雙重程序保障。
林明昕，註 19，頁 9-10。

不問其是否屬於刑事被告之身分，除須有法律之依據外，尚須分別踐行必要之司法程序或其他正當法律程序，始得為之（本院釋字第三八四號解釋參照）。此項程序固屬憲法保留之範疇，縱係立法機關亦不得制定法律而遽予剝奪；惟刑事被告與非刑事被告之人身自由限制，畢竟有其本質上之差異，是其必須踐行之司法程序或其他正當法律程序，自非均須同一不可。**管收**係於一定期間內拘束人民身體自由於一定之處所，雖亦屬憲法第八條第一項所規定之「拘禁」，然與刑事程序之羈押，目的上尚屬有間。羈押重在程序之保全，即保全被告俾其於整個刑事程序均能始終到場，以利偵查、審判之有效進行，以及判決確定後之能有效執行；管收則有如前述，目的在使其為金錢給付義務之履行，為間接執行方法之一種，並非在保全其身體，故其所踐行之司法程序自無須與羈押完全相同。然雖如此，其**於決定管收之前，仍應踐行必要之司法程序則無二致，此即由中立、公正第三者之法院審問，並使法定義務人到場為程序之參與**，除藉之以明管收之是否合乎法定要件暨有無管收之必要外，並使法定義務人得有防禦之機會，提出有利之相關抗辯以供法院調查，期以實現憲法對人身自由之保障。

(3) 非處罰（安置、收容、隔離）：即時司法救濟＋正當法律程序

釋字第 690 號理由書第 5、6 段

人身自由為重要之基本人權，應受充分之保護，對人身自由之剝奪或限制尤應遵循正當法律程序之意旨，惟相關程序規範是否正當、合理，除考量憲法有無特別規定及所涉基本權之種類外，尚須視案件涉及之**事物領域、侵害基本權之強度與範圍、所欲追求之公共利益、有無替代程序及各項可能程序之成本**等因素，綜合判斷而為認定（本院釋字第六三九號解釋參照）。**強制隔離既以保障人民生命與身體健康為目的，而與刑事處罰之本質不同，已如前述，故其所須踐行之正當法律程序，自毋須與刑事處罰之限制被告人身自由所須踐行之程序相類**。強制隔離與其他防疫之決定，應由**專業主管機關基於醫療與公共衛生之知識，通過嚴謹之組織程序，衡酌傳染病疫情之嚴重性及其他各種情況，作成客觀之決定**，以確保其正確性，與必須由中立、公正第三者之法院就是否拘禁加以審問作成決定之情形有別。且疫情之防治貴在迅速採行正確之措施，方得以克竟其功。……對傳染病相關防治措施，自以主管機關較為專業，**由專業之主管機關衡酌傳染病疫情之嚴重性及其他各種情況，決定施行必要之強制隔離處置，自較由法院決定能收迅速防治之功**。另就法制面而言，該管主管機關作成前述處分時，亦應依行政程序法及其他法律所規定之相關程序而為之。受令遷入指定之處所強制隔離者**如不服該管主管機關之處分，仍得依行政爭訟程序訴求救濟**。是系爭規定之強制隔離

處置雖非由法院決定，與憲法第八條正當法律程序保障人民身體自由之意旨尚無違背。

系爭規定未就強制隔離之期間予以規範，及非由法院決定施行強制隔離處置，固不影響其合憲性，惟曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，於受強制隔離處置時，人身自由即遭受剝奪，為使其受隔離之期間能合理而不過長，**仍宜明確規範強制隔離應有合理之最長期限，及決定施行強制隔離處置相關之組織、程序等辦法以資依循，並建立受隔離者或其親屬不服得及時請求法院救濟**，暨對前述受強制隔離者予以合理補償之機制，相關機關宜儘速通盤檢討傳染病防治法制。

釋字第 708 號理由書第 3、4 段

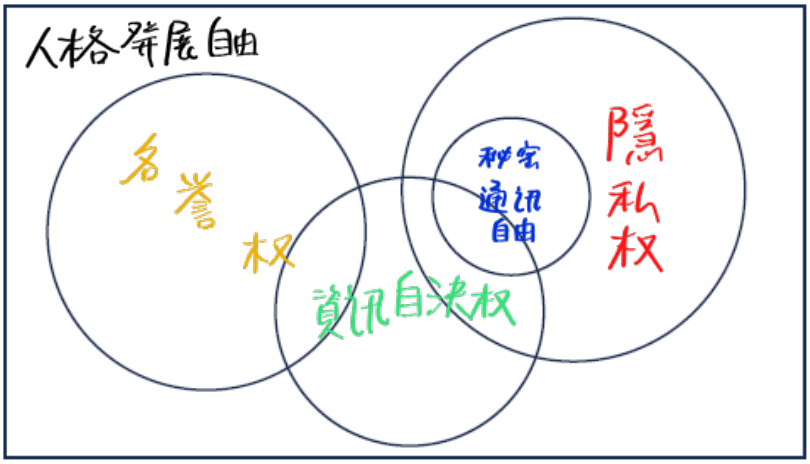
系爭規定所稱之「收容」，雖與刑事羈押或處罰之性質不同，但仍係於一定期間拘束受收容外國人於一定處所，使其與外界隔離……亦屬剝奪人身自由之一種態樣……自須踐行必要之司法程序或其他正當法律程序。惟刑事被告與非刑事被告之人身自由限制，在目的、方式與程度上畢竟有其差異，是其踐行之司法程序或其他正當法律程序，自非均須同一不可（本院釋字第五八八號解釋參照）。查外國人並無自由進入我國國境之權利，而入出國及移民署依系爭規定收容外國人之目的，在儘速將外國人遣送出國，非為逮捕拘禁犯罪嫌疑人……系爭規定賦予該署**合理之遣送作業期間**，且於此短暫期間內得處分暫時收容該外國人，以防範其脫逃，俾能迅速將該外國人遣送出國，當屬合理、必要，亦屬國家主權之行使，並不違反憲法第八條第一項保障人身自由之意旨，是**此暫時收容之處分部分，尚無須經由法院為之**。惟基於上述憲法意旨，為落實**即時有效之保障功能**，對上述處分仍應賦予受暫時收容之外國人有立即**聲請法院審查決定之救濟機會**，倘受收容人於暫時收容期間內，對於暫時收容處分表示不服，或要求由法院審查決定是否予以收容，入出國及移民署應即於二十四小時內將受收容人移送法院迅速裁定是否予以收容；且於處分或裁定收容之後，亦應即以受收容之外國人可理解之語言及書面，告知其處分收容之原因、法律依據及不服處分之司法救濟途徑，並通知其指定之在臺親友或其原籍國駐華使領館或授權機關，俾受收容人善用上述救濟程序，得即時有效維護其權益，方符上開憲法保障人身自由之意旨。

至受收容人於暫時收容期間內，未表示不服或要求由法院審查決定是否收容，且暫時收容期間將屆滿者，**入出國及移民署倘認有繼續收容之必要，因事關人身自由之長期剝奪**，基於上述憲法保障人身自由之正當法律程序之要求，系爭規定關於逾越前述暫時收容期間之收容部分，**自應由公正、獨立審判之法院依法審查決定**。故入出國及移民署應於暫時收

容期間屆滿之前，將受暫時收容人移送法院聲請裁定收容，始能續予收容；嗣後如依法有延長收容之必要者，亦同。
就非刑事或其他處罰的人身自由剝奪，釋字 690 以「專業嚴謹組織程序」及行政爭訟程序的救濟取代法官保留，對法官保留的意旨似有誤解，其不等於「專業保留」，亦不等同基於訴訟權的事後救濟。釋字 708、710 則將釋字 690 中僅具警告性的「即時有效司法救濟」提升為憲法誡命，並加上「法院決定續行與否」的要求，一定程度導正釋字 690 自憲法第 8 條基本精神的偏離。

肆、 隱私權

一、 人格發展自由概論



- 人格發展條件：人格發展自由
- 人格發展條件＋私密空間：隱私權→防止侵入、揭露
- 人格發展條件＋私密通訊空間：秘密通訊自由→防止侵入、揭露
- 人格發展條件＋資訊掌控：資訊自決權→防止揭露、使用
- 人格發展條件＋社會評價：名譽權→防止貶損

釋字第 603 號理由書第 8 段 維護人性尊嚴與尊重**人格自由發展**，乃自由民主憲政秩序之核心價值。隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障**個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自**

主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障（本院釋字第五八五號解釋參照），其中包含個人自主控制其個人資料之資訊隱私權，保障人民決定是否揭露其個人資料、及在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權，並保障人民對其個人資料之使用有知悉與控制權及資料記載錯誤之更正權。

釋字第 631 號理由書第 2 段

憲法第十二條規定：「人民有秘密通訊之自由。」旨在確保人民就**通訊之有無、對象、時間、方式及內容等事項**，有不受國家及他人任意侵擾之權利。此項**秘密通訊自由乃憲法保障隱私權之具體態樣之一**，為維護人性尊嚴、個人主體性及人格發展之完整，並為保障個人生活私密領域免於國家、他人侵擾及維護個人資料之自主控制，所不可或缺之基本權利（本院釋字第六０三號解釋參照），憲法第十二條特予明定。

113 年憲判字第 3 號理由第 36、37 段[21]

按人民之名譽權，係保障**個人於社會生活中之人格整體評價，不受惡意貶抑、減損**。名譽權雖非憲法明文規定之權利，但向為大法官解釋及本庭判決承認屬憲法第 22 條所保障之非明文權利（本庭 112 年憲判字第 8 號判決參照）。……（一般）人格權之保障範圍本包括個人名譽，而**名譽權則是（一般）人格權在社會評價領域具體化後，所衍生之特定人格權。**

注意上揭文氏圖中哪兩個圓圈沒有重疊！「隱私權涉及個人生活的公私界線，旨在保護個人生活領域免於不當公開／揭露」[22]，故揭露本身即是干預，至於揭露後衍生的社會評價在所不問；「名譽權則涉及社會評價的真假區分，旨在保障個人人格免於『名不符實』的錯誤社會評價」[23]，故難堪但真實的評價仍非屬名譽權防禦的範圍。兩者不應混淆。

[21] 該號判決進一步將名譽權的保障範圍區分為社會名譽、名譽情感及名譽人格：社會名譽又稱外部名譽，係指第三人對於一人之客觀評價，且不論被害人為自然人或法人，皆有其社會名譽。於被害人為自然人之情形，則另有其名譽感情及名譽人格。名譽感情指一人內心對於自我名譽之主觀期待及感受，與上開社會名譽俱屬經驗性概念。名譽人格則指一人在其社會生存中，應受他人平等對待及尊重，不受恣意歧視或貶抑之主體地位，係屬規範性概念。此項平等主體地位不僅與一人之人格發展有密切關係，且攸關其社會成員地位之平等，應認係名譽權所保障人格法益之核心所在。參理由第 36-47 段。

[22] 蘇慧婕，言論自由的民主工具化——憲法法庭 112 年憲判字第 8 號判決評析，裁判時報，142 期，頁 22，2024 年。蘇老師因此批評 112 年憲判字第 8 號就刑法第 310 條第 3 項但書「純涉私德」條款的判斷混淆名譽權和隱私權的保障範圍。

[23] 蘇慧婕，註 22。

二、 保障範圍

（一）空間隱私：私密空間→公共空間

> 釋字第 689 號理由書第 7 段
>
> 個人之私人生活及社會活動，隨時受他人持續注視、監看、監聽或公開揭露，其言行舉止及人際互動即難自由從事，致影響其人格之自由發展。尤以現今**資訊科技高度發展**及相關設備之方便取得，個人之私人活動受注視、監看、監聽或公開揭露等侵擾之可能大為增加，個人之私人活動及隱私受保護之需要，亦隨之提升。是**個人縱於公共場域中，亦應享有依社會通念得不受他人持續注視、監看、監聽、接近等侵擾之私人活動領域及個人資料自主，而受法律所保護。惟在公共場域中個人所得主張不受此等侵擾之自由，以得合理期待於他人者為限，亦即不僅其不受侵擾之期待已表現於外，且該期待須依社會通念認為合理者。**

1. 意義：**私密空間**中對資訊的絕對控制，以發展私人生活（「家宅」的功能理解）
2. 擴張：因應資訊科技發展弱化個人資訊控制能力，隱私權保障應擴及公共空間中的活動。
3. 界限：人格發展關聯性→**合理隱私期待**

（二）資訊隱私：私密資訊→可識別資訊

> 111 年憲判字第 13 號理由第 31、32、35 段
>
> 就個人自主控制個資之資訊隱私權而言，乃保障人民決定是否揭露其個資、及**在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權**，並保障人民對其個資之使用有**知悉與控制權及資料記載錯誤之更正權**（司法院釋字第 603 號解釋參照）。進一步而言，資訊隱私權保障當事人原則上就其個資，**於受利用之前，有同意利用與否之事前控制權，以及受利用中、後之事後控制權**。除當事人就獲其同意或符合特定要件而允許未獲當事人同意而經蒐集、處理及利用之個資，仍具事後控制權外，**事後控制權之內涵並應包括請求刪除、停止利用或限制利用個資之權利。**
>
> 個資若經處理，依其資料型態與資料本質，客觀上仍有還原而間接識別當事人之可能時，無論還原識別之方法難易，若以特定方法還原而可間接識別該個人者，其仍屬個資。當事人就此類資料之自主控制權，仍受憲法資訊隱私權之保障。反之，經處理之資料於**客觀上無還原識別個人**

之可能時，即已喪失個資之本質，當事人就該資訊自不再受憲法第 22 條個人資訊隱私權之保障。

1. 意義：個人資料自主控制，以展現**社會**自我
2. 內涵
   (1) 事前：是否、何時、何種範圍、何種方式、向何人揭露
   (2) 事後：使用的知悉、控制、更正
   (3) 非本質論：以人格發展關聯性為判斷標準
3. 擴張：因應資訊科技發展模糊公私領域的界線，隱私權保障應擴及足以連結至個人的資訊。
4. 界限：人格發展關聯性→**可識別性**

釋字第 603 號林子儀大法官協同意見書

所謂**已公開的資訊即不受隱私權之保障，並非的論**。至多僅得謂：已為眾所週知或相當多數之人所知之資訊，或個人自願公開之資訊，並在其授權公開之範圍內，即難以再主張受到隱私權之侵害。且基於重視個人資訊隱私權之保障之觀點，縱係個人自願公開資訊下，也不意謂第一次的授權之後，個人對其自願公開之資訊即因此完全喪失控制，而不能對違反其授權目的或範圍的侵害行為有所主張。

將資訊隱私權所欲保護之對象限於個人私密之資訊，毋寧過分限縮，而不能因應現今資訊科技發展所可能對個人造成之侵害。蓋**隨電腦處理資訊技術的發達，過去所無法處理之零碎、片段、無意義的個人資料，在現今即能快速地彼此串連**、**比對歸檔與系統化。當大量關乎個人但看似中性無害的資訊累積在一起時，個人長期的行動軌跡便呼之欲出。誰掌握了這些技術與資訊，便掌握了監看他人的權力**。故為因應國家和私人握有建立並解讀個人資訊檔案的能力，避免人時時處於透明與被監視的隱憂之中，**隱私權保障的範圍也應該隨之擴張到非私密或非敏感性質的個人資料保護**。

三、 權利干預

（一）空間隱私

1. 家宅空間：搜索、監視、監聽

2. 公共空間

(1) 國家：臨檢（J535）、監聽、監視（人臉辨識、步態辨識）

(2) 他人：監聽、監視、跟追（J689）

（二）資訊隱私

1. 敏感個資蒐集、建檔（111 憲判 13）

2. 生物特徵蒐集、建檔（J603）

3. GPS 紀錄蒐集、建檔

4. 數位足跡蒐集、建檔

→巨量資料蒐集+分析（機器學習、自動化演算）

→social profiling; social ranking

四、 重要實務見解

（一）釋字第 689 號新聞記者跟追

＊爭議來自社維法第 89 條第 2 款適用於「有正當理由」之新聞跟追，原判決未考量**基本權放射效力**而為**憲法取向解釋**，致生適用上違憲，憲訴新制下應提起**裁判憲法審查**。

1. 國家行為：社維法第 89 條第 2 款[24]限制新聞採訪跟追行為（stalking）

2. 基本權干預：新聞記者的行動自由（憲 22 一般行為自由）、新聞自由（憲 11）

3. 比例原則

(1) 立法目的：人民免於身心傷害之身體權、行動自由、生活私密領域不受侵擾自由、個資自主權→以得合理期待者為限

(2) 目的手段：具合理關聯

(3) 基本權衝突之個案衡量

A. 採訪者新聞自由 vs 被跟追人身體權、行動自由：如跟追已達緊迫程度，而可能為即被跟追人身心安全之身體權或行動自由，

[24] 社維法第 89 條第 2 款：「有下列各款行為之一者，處新臺幣三萬元以下罰鍰或申誡：……二、無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。」

即不足以正當化。

B. 採訪者新聞自由 vs 被跟追人生活私密領域不受侵擾自由、個人資料自主：衡量採訪內容是否具一定公益性、私人活動領域受干擾之程度、跟追行為依社會通念是否不能容忍

理由書第 9、10 段

系爭規定雖限制跟追人之行動自由，惟其係為保障被跟追者憲法上之重要自由權利，而所限制者為依社會通念不能容忍之跟追行為，對該行為之限制與上開目的之達成有**合理關聯**，且該限制經利益衡量後尚屬輕微，**難謂過當**。況依系爭規定，須先經勸阻，而行為人仍繼續跟追，始予處罰，已使行為人得適時終止跟追行為而避免受處罰。是系爭規定核與憲法第二十三條比例原則尚無牴觸。至系爭規定對於跟追行為之限制，如影響跟追人行使其他憲法所保障之權利，其限制是否合憲，自應為進一步之審查。適用上違憲而干預其他基本權

考徵系爭規定之制定，原非針對新聞採訪行為所為之限制，其對新聞採訪行為所造成之限制，如係追求重要公益，且所採手段與目的之達成間具有實質關聯，即與比例原則無違。A 新聞採訪者縱為採訪新聞而為跟追，如其跟追已達緊迫程度，而可能危及被跟追人身心安全之身體權或行動自由時，即非足以合理化之正當理由，系爭規定授權警察及時介入、制止，要不能謂與憲法第十一條保障新聞採訪自由之意旨有違。B 新聞採訪者之跟追行為，如侵擾個人於公共場域中得合理期待其私密領域不受他人干擾之自由或個人資料自主，其行為是否受系爭規定所限制，則須**衡量採訪內容是否具一定公益性與私人活動領域受干擾之程度**，而為合理判斷[25]，如依社會通念所認非屬不能容忍者，其跟追行為即非在系爭規定處罰之列。

（二）釋字第 603 號按捺指紋換發身分證

1. 國家行為：戶籍法第 8 條第 2、3 項捺指紋始核發身分證之規定

2. 基本權干預：指紋隱私與身分證（及出示身分證始得行使的權利）不可兼得，形同強制按捺並錄存指紋

3. 比例原則

[25] 對此判斷，本號解釋基於憲法上正當法律程序而謂：鑑於其所涉判斷與權衡之複雜性，並斟酌法院與警察機關職掌、專業、功能等之不同，為使國家機關發揮最有效之功能，並確保新聞採訪之自由及維護個人之私密領域及個人資料自主，是否宜由法院直接作裁罰之決定，相關機關應予檢討修法，或另定專法以為周全規定，併此敘明。（理由書第 11 段）

(1) 審查標準

理由書第 9、11 段 該法律是否符合憲法第二十三條之規定，則應就國家蒐集、利用、揭露個人資訊所能獲得之公益與對資訊隱私之主體所構成之侵害，通盤衡酌考量。並就所蒐集個人資訊之性質**是否涉及私密敏感事項、或雖非私密敏感但易與其他資料結合為詳細之個人檔案**，於具體個案中，採取不同密度之審查。 指紋係個人身體之生物特徵，因其具有**人各不同、終身不變之特質，故一旦與個人身分連結，即屬具備高度人別辨識功能**之一種個人資訊。由於指紋**觸碰留痕**之特質，故經由建檔指紋之比對，將使指紋居於**開啟完整個人檔案鎖鑰之地位**。因指紋具上述諸種特性，故國家藉由身分確認而蒐集個人指紋並建檔管理者，足使指紋形成得以監控個人之**敏感性資訊**。國家如以強制之方法大規模蒐集國民之指紋資料，則其資訊蒐集應屬與**重大公益之目的**之達成，具備**密切關聯之侵害較小手段**，並以法律明確規定之，以符合憲法第二十二條、第二十三條之意旨。
釋字第 603 號林子儀大法官協同意見書 多數意見似主張指紋之性質非如醫療紀錄、性傾向、宗教信仰或政治立場般敏感，致個人有強烈的意願保持隱密不欲人知；且指紋亦不如 DNA 遺傳訊息般帶有個人豐富之遺傳資訊在內；故就系爭法律規定是否合憲之審查，即未採嚴格之審查標準，而以中度審查標準審查其合憲性。……本席基於現代資訊科技的應用、前述指紋之特性、人別辨識功能、與作為開啟個人檔案之鑰的可能用途，而認為**個人指紋資訊為相當敏感之個人資訊**[26]，是以法律對之強制蒐集，就該法律之是否合憲之審查即主張**應採取嚴格之審查標準**予以審查。

(2) 手段目的關聯

A. 防偽、防止冒領冒用→高度資安風險為代價，無必要

B. 身份辨識→損益失衡、手段過當

[26] 多數意見既考量個資性質是否涉及私密敏感事項，從而採中度審查標準，言下之意指紋應非屬私密敏感資訊；然其又謂指紋因其個人檔案鎖鑰之地位，足以形成敏感個資，所以到底是敏感還不敏感？此處應是大法官共筆未查、一語多義：就資訊內容而言指紋固難謂有何私密敏感可言，但自資訊特性以觀就相當敏感了。這從林子儀大法官意見書即可明白。

(3) 資訊**使用**之限制：法律明定蒐集目的、明文禁止目的外使用、確保資訊正確安全、組織程序必要防護

> 釋字第 603 號林子儀大法官協同意見書
>
> 本案令人尤其疑懼之處，在於立法部門對此一影響重大的決策欠缺**民主程序中必要的審議思辯**在先，而行政部門亦難以提出得**確保資訊安全管理及正當使用的機制**在後。
>
> 立法部門之所以必須就蒐集資料之目的與範圍，事先予以明確界定，除如多數意見所指，惟有如此才能對行政機關形成有意義的控管與授權、司法部門才能夠基此判斷行政部門於個案中的資訊運用是否正當。更重要的是，只有事前確立的明確立法目的、並以此而就資訊蒐集之範圍及資訊運用之方式予以明確授權和管制，國家對人民才算已盡最低限度的告知義務。蓋資訊隱私權重要的意義之一，在於尊重、保護個人自主選擇的權利，但有意義的選擇須事先獲得充分翔實的資訊。
>
> 至於行政部門就其所蒐集之指紋資訊，如何方屬正當使用之問題，行政部門乃於言詞辯論中援引電腦處理個人資料保護法第八條的概括規定，作為一般性授權基礎……不僅不能有效規範**跨目的、跨機關**之使用，反而將依法得跨目的使用的**例外情形，轉變成原則**上得跨目的使用之授權規定。
>
> 人民面對國家資訊蒐集的無奈之一是，一旦**個人資訊脫手，個人其實已經很難再有控制之可能**。且除非具體問題發生，否則人民對於機關內部的資訊保管及運用情形，實則一無所悉，也無從確認國家是否良好地保護其資訊安全並予以正當使用。本案突顯行政上對個人資料使用範圍及目的低度管制的實務，尤其是一重大警訊。如果行政機關能夠事先**對資料庫建立法制、技術、組織及程序上的種種安全閥，以確保所蒐集資料之 安全與正當使用，例如建立行政上之獨立管制機關，代替缺乏專業能力的一般民眾監督政府資料庫之運用情形**，而非率爾大規模啟動強制性的指紋資料蒐集，而對嗣後資訊保管與運用之管制草草帶過，則國家蒐集資訊之正當性亦將隨之提高。

（三）111 年憲判字第 13 號健保資料庫案

1. 國家行為：健保法第 79 條第 2 項[27]準用個資法第 6 條第 1 項[28]但書第

[27] 健保法第 79 條第 2 項：「保險人依前項規定所取得之資料，應盡善良管理人之注意義務；相關資料之保存、利用等事項，應依個人資料保護法之規定為之。」

[28] 個資法第 6 條第 1 項第 4 款：

4 款

2. 基本權干預：健保資料庫的建置及開放目的外利用限制資訊隱私權之事後控制權

3. 法律保留

理由第 64-67 段

特定基本權利就其性質或保障內容，需仰賴國家積極提供適當組織與程序規定，始能獲得具體實踐者，國家亦應以法律或法律明確授權之命令為之，始符合法治國家法律保留原則之要求。……基於個人健保資料所涉資訊隱私權之重要性，國家蒐集個人健保資料，構成對個人資訊隱私權之限制，即應有法律保留原則之適用；另**就國家將強制蒐集之個人健保資料進一步儲存、處理，建立成資料庫，甚至對外傳輸，作原始蒐集目的外之利用而言，因已完全脫離個別資訊主體控制範圍，是如何確保該業已逸脫個人控制範圍之個人健保資料，不受濫用或不當洩漏，而導致資訊隱私權之侵害繼續擴大，國家亦有義務以法律積極建置適當之組織與程序性防護機制，**以符法律保留原則之意旨……由系爭規定二及其他相關法律規定整體觀察，關於涉及個人資訊隱私權限制，應受法律保留原則拘束之健保署就個人健保資料之對外傳輸或提供利用相關行為，其所應遵循之**法定要件與正當程序，包括上開資料以資料庫儲存、處理、對外傳輸及對外提供利用之主體、目的、要件、範圍及方式，暨相關組織上及程序上之監督防護機制等重要事項，均未見相關法律有所規定**，而充其量僅有若干非法律位階、尚不完足之衛福部與健保署自訂之行政規則規定，即均仍欠缺法律位階之明確規定，於此範圍內，不符憲法第 23 條法律保留原則之要求。

4. 比例原則

(1) 審查標準

理由第 45 段

個人健保資料乃屬得深入解讀並預測資料當事人人格與身心狀況，進而**模擬建構其人格圖像**之重要個資，其具有**私密敏感與潛在延伸影響資料當事人之社會、經濟生活**（例如保險或就業）之特質。此等個人

「有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料（按：特種個資），不得蒐集、處理或利用。但有下列情形之一者，不在此限：

四、**公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要**（按：資料最小化），**且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別**特定之當事人（按：去識別化：提供者或蒐集者）。」

健保資料如受侵害，其所致生危害結果之嚴重性，**尤甚於指紋**。本庭爰認就系爭規定一是否合於比例原則，應採較指紋個資蒐集更高之**嚴格標準**予以審查。即其目的應係為追求特別重要之公益，其所採取手段應有助於目的之達成，且為最小侵害手段，所犧牲之私益與所追求之公益間應具相稱性，始與比例原則相符。

(2) 目的審查：透過統計或學術研究，促成法定目的即醫療、衛生發展→屬特別重要公益

(3) 手段審查

A. 適當

B. 必要：已符合最小蒐用原則（主體、目的及範圍限制）與去識別化義務（已大幅提高識別門檻，若要求完全不具還原識別可能將失去學術樣本價值）

C. 衡平：公眾健康、社會安全＞個人敏感資訊隱私權

5. 組織及程序上之防護措施

理由第 61、62 段

就資訊隱私權之保障而言，除應以法律明確訂定蒐用個資之目的及要件外，應配合當代科技發展，運用足以確保資訊正確及安全之方式，並對所蒐集之個資採取組織上與程序上必要之防護措施，以符憲法保障人民資訊隱私權之本旨（司法院釋字第 603 號解釋參照）。前述組織上與程序上必要之防護措施中，**個資保護之獨立監督機制**為重要之關鍵制度。此一獨立監督機制之目的，在於**確保個資蒐用者對於個資之蒐用，均符合相關法令之規定**，以增強個資蒐用之合法性與可信度，尤其個人健保資料業已逸脫個人控制範圍，如何避免其不受濫用或不當洩漏，更有賴獨立機制之監督。又其審酌事項尤應包括特予**注意個案利用之申請，其具體情狀是否合於比例原則**……以使所犧牲之法益與所欲保護之法益不致輕重不相稱而失衡，暨是否確有強制蒐用必要等事項之審酌即屬之。……個資法暨其他相關法律規定整體觀察，均欠缺個資保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障自有不足，而有**違憲之虞**。

6. 事後退出權

理由第 69-71 段

憲法第 22 條個人資訊隱私權保障當事人原則上應有事後控制權，且當事

人就獲其同意或符合特定要件而允許未獲當事人同意而經蒐集、處理及利用之個資，仍具事後控制權，不因其曾表示同意或因符合強制蒐用要件，當事人即喪失請求刪除、停止利用或限制利用個資之權利。……由相關法制整體觀察，卻未見立法者依所保護個人資訊隱私權與利用目的間法益輕重及手段之必要性，而為適當權衡及區分，一律未許當事人得請求停止利用，停止利用應遵循之相關程序亦無規定，亦即**欠缺當事人得請求停止利用之相關規定**，顯然於個人資訊隱私權之保護有所不足；於此範圍內，**違反憲法第 22 條保障人民資訊隱私權之意旨**。

7. 批評： 111 年憲判字第 13 號黃昭元大法官不同意見書

(1) 目的審查：將所有基於醫療或衛生之統計及學術研究都一律評價為特別重要公益，有失籠統、過寬。

(2) 手段審查：假嚴格的放水審查標準

A. 去識別化？

按現行科學及技術條件下的匿名化技術，已越來越難以達成完全的匿名化（指徹底的去連結，而無從再還原識別當事人）。因此，所謂**去識別化其實比較像是個光譜**，有些去識別化方式仍容易還原連結，有些去識別方式則需耗費較多成本方能識別，但最終仍能識別。就此而言，系爭個資法規定**並未進一步針對不同風險程度之目的外利用情形，要求或區別不同的去識別化方法**，致健保資料之主管機關享有相當大的選擇空間，而有侵害人民資訊隱私權之風險。……健保署在健康保險個資的儲存、處理、利用上，也只是刪除當事人之「姓名」及「住址」二個變項資料，至於其他私密敏感資料（例如：身分證字號、醫療院所代碼、申報日期、就醫日期等），則以「專屬代碼」的方式（即假名化），儲存於健保資料庫或提供外部使用時，分別進行多次編碼。雖然健保署已經刪除上述姓名及住址二個變項資料，但個人健保資料中僅以專屬代碼呈現的其他變項資料（例如：身分證字號），因未永久斷開其與個資主體間之連結，如透過與其他資料庫內資料的比對，**在技術上依然有可能輕易識別其個資主體，而不再具有假名化之效果**。

B. 最小蒐用原則？

不同學術研究之目的及對象均有所不同，不同之研究對於資料數量的需求也會有所不同。因此，在手段與目的關聯性之審查上，

至少應要求並限制資料提供機關，應就不同的學術研究，僅提供其所需之不同數量的個人資料。此即最小蒐用原則，亦即必要性原則在個人資料保護法制的具體展現。就此而言，系爭規定不僅在表面上對於所提供之資料數量並沒有限制，在實務運作上，健保署於實際提供健保資料時，也僅有「兩百萬人抽樣檔」及「全人口檔」的粗略分類，而無其他數量的抽樣檔，可對應不同研究目的、涉及之需求，以致可能提供明顯大於學術研究者需求之個人資料。

C. 事後退出權？→有退出權保障始符合衡平性原則

考量人民對於國家之強制蒐集健保資料並建置健保資料庫予以利用，早已無從行使其事前同意權，在制度上自有必要賦予個別人民行使事後之退出權，以此平衡人民事前同意權之喪失，這可說是人民對其個人健保**資料自主控制權的最後一道防衛**。……本判決係區別個資法和健保法而分別審查，並於主文第一項宣告前者不違反比例原則而合憲，於主文第四項宣告後者因欠缺退出權而部分違憲。本席認為如此切割並不妥當，也是一種**鋸箭法式的審查**。……就本案所涉個人健保資料之利用而言，系爭個資法規定同時也是本案原因案件裁判所直接適用之法律，無從與健保法相關規定切割而分別審查。故如本判決主文第四項認為健保法及相關規定欠缺退出權而違憲，由於個資法本身也欠缺有關退出權之規定，當然也應該是主文第四項違憲審查及宣告的範圍所及。在法理上，應**不可能如本判決般，一方面在主文第四項宣告相關法制（解釋上應包括個資法及健保法等）因欠缺退出權規定而違憲，然在主文第一項竟仍宣告同樣欠缺退出權規定之系爭個資法規定不違反比例原則而合憲**。

(3) 獨立監督機制：違憲「之虞」？[29]

[29]（比較好懂的）相近見解參同判決許宗力大法官不同意見書：該適當組織與程序保護規定之設置義務一方面來自憲法對於國家侵害或限制人民基本權利時所提出必須遵守之正當法律程序要求，二方面也因此**連結憲法比例原則**，亦即判斷限制人民基本權利之手段是否為最小侵害時，不僅是限制手段本身，同時亦須衡酌有無相應的適當組織與程序保障機制。……本席認為立法者於組織與程序規範設計之裁量空間應收縮至零，且壓縮到要合乎正當程序要求只剩唯一的選擇，也就是**建置一套含獨立第三方監督機制之組織與程序保護規定，否則即違反憲法正當程序要求**。因在**作為資訊主體之人民無從知悉、不知情的情況**下，唯有獨立第三方機制之存在，才能提供對 掌握人民健保個資的國家，以及使用人民健保個資的學研單位，相對有效的監督與制衡，人民的資訊隱私權也因此才比較能獲得保障。……無奈本判決多數意見不僅不認為欠缺個資保護之獨立監督機制違憲，只願承認有違憲之虞，且**將系爭規定與組織、程序保護機制分開評價，認為後者僅僅是整部個資法規範不足的問題，不影響國家目的外利用健保個資，而認定系爭規定不違反比**

> 個人資料保護所涉及的憲法核心爭點，本來應該是前述資料自主權（從事前同意到事後退出的自主決定權）、目的之審查（尤其是目的外利用）、手段之審查（例如去識別化之方法及效果等）等實體問題。如果只要求或過度強調獨立監督機制，反而會有「**實體權利保障之程序化**」，甚至「空洞化」的疑慮，也就是以國家權力分立層面的組織及程序保障（亦即國家機關間之相互制衡），來迴避甚至取代有關個人權利與國家權力間實體界限之劃分及審查。換言之，獨立監督機制的保障至多就是正當法律程序之事前及事中保障，仍不足以也不應因而取代各項權利之實體保障及其審查。但無魚，蝦嘛好，本判決主文第一項就系爭個資法規定是否違反比例原則之實體審查部分，既然已經輕輕放下，概認合憲；則主文第二項就獨立監督機制之建置，**至少也應該宣告違憲**，始足以對資訊隱私權提供最低限度之憲法保障。

(4) 健保資料庫之建置及利用欠缺專法明文規定或授權，牴觸釋字 603 意旨

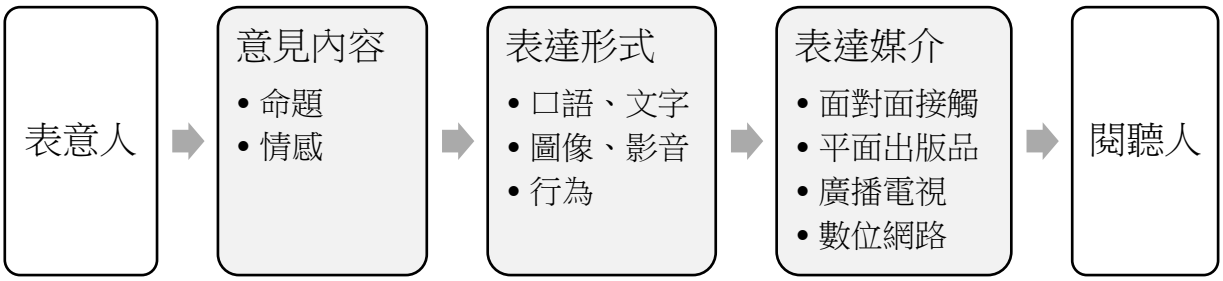
> 依釋字第 603 號解釋之意旨，國家對於大規模資料庫之建置，包括本案所涉及之全民健保資料庫，本即**應有特別法**（如人體生物資料庫管理條例）**為依據，且應明文規定其法定目的，同時禁止法定目的外利用**。個資法既然不是上述解釋所稱之專法，健保法第 79 條第 2 項又以此一般性、框架性法律為其提供第三人目的外利用之唯一法律依據，故在此範圍內，系爭個資法連同系爭健保法規定均因違反上述「應以特定法律明定」之要求而違憲。

伍、 言論自由

一、 保障範圍

（一）表意自由的本質要素→*人際溝通的自由，而非喃喃自語的自由*

例原則。如此割裂審查的結果，無異表示國家可以先上車後補票（甚至何時才補票仍屬未知），也就是允許國家可以強制蒐集人民健保個資後，即逕行為目的外利用，無論獨立第三方監督機制是否已經建置完備，「先做了再說」……。



1. 表意自由的功能

(1) 表意人：人格表達、實現自我→內容不設限

(2) 意見內容：追求真理

(3) 閱聽人：社會參與、健全民主

2. 表意自由的類型

(1) 意見內容：學術自由、新聞自由

(2) 表達形式：集會遊行自由；講學、著作、出版自由

(3) 表達媒介：廣電自由

釋字第 445 號理由書第 7 段

憲法第十四條規定人民有集會之自由，此與憲法第十一條規定之言論、講學、著作及出版之自由，同屬表現自由之範疇。本於主權在民之理念，人民享有自由討論、充分表達意見之權利，方能**探究事實，發見真理，並經由民主程序形成公意，制定政策或法律**。因此，表現自由為實施民主政治最重要的基本人權。國家所以保障人民之此項權利，乃**以尊重個人獨立存在之尊嚴及自由活動之自主權為目的**。其中**集會自由主要係人民以行動表現言論自由；至於講學、著作、出版自由係以言論或文字表達其意見**，對於**一般不易接近或使用媒體言論管道之人**，集會自由係保障其公開表達意見之重要途徑。

釋字第 689 號理由書第 5 段

為確保新聞媒體能提供具新聞價值之多元資訊，**促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展**，新聞自由乃不可或缺之機制，應受憲法第十一條所保障。新聞採訪行為則為提供新聞報導內容所不可或缺之資訊蒐集、查證行為，自應為新聞自由所保障之範疇。又新聞自由所保障之新聞採訪自由並非僅保障隸屬於新聞機構之新聞記者之採訪行為，亦保障**一般人**為提供具新聞價值之資訊於眾，或為促進公共事務討論以監督政府，而從事之新聞採訪行為。

（二）權利主體

1. 自然人
2. 法人、人民團體
3. 人工智慧系統？

（三）權利客體：言論＝意見（思想內容）的表達

1. 表達形式：口語、文字、圖像、影音、身體動靜舉止、物品利用毀棄
2. 意見內容：事實陳述、價值判斷，不論其「價值」高低→謊言？

> 112 年憲判字第 8 號理由第 73 段
>
> 基於明知或重大輕率之惡意而散播假新聞或假訊息，本不受憲法言論自由之保障。

3. 消極言論自由：意見（思想自由）的不表達

> 111 年憲判字第 2 號理由第 7 段
>
> 憲法第 11 條保障人民有積極表意之自由，及消極不表意之言論自由，其保障之內容包括主觀意見之表達及客觀事實之陳述（司法院釋字第 577 號解釋參照）。

二、 權利干預

（一）消極言論自由干預：強制表達意見、強制揭露資訊

（二）事前審查：未經事前許可不得發表

（三）言論時間、地點、方式的管制（內容中立的管制）e.g.禁止噪音

（四）言論內容的事後處罰

1. 言論觀點的歧視 e.g. 禁止主張共產言論、分裂國土的言論
2. 言論溝通效果的限制 e.g. 侵害名譽、隱私、性自主、公共秩序、國家安全……

（五）表意人的歧視→言論自由與平等權競合[30]

[30] 另參本講義頁 20。又值得注意的是，釋字 794 亦涉及表意人歧視（菸商），則係平行審查並採

112 年憲判字第 17 號理由第 18 段

系爭規定係**限制醫療廣告之主體，與前開大法官解釋，係針對立法者對於言論內容之限制所為闡釋，二者雖有不同**，然系爭規定所禁止者，仍與言論自由之限制有關，故前開大法官所闡釋之審查標準，**亦可援用**於本件。

三、 干預的正當化

（一）形式要件：法律保留（及授權明確性）

（二）實體要件：雙軌理論＋雙／三階理論（審查標準類型化）＋比例原則

1. 事前審查？

釋字第 744 號理由書第 3 段

系爭規定係就化粧品廣告採取**事前審查制**，已涉及對化粧品廠商言論自由及人民取得充分資訊機會之限制。按化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，**原則上應為違憲**。系爭規定之立法資料須足以支持對化粧品廣告之事前審查，係為防免人民生命、身體、健康遭受**直接、立即及難以回復危害之特別重要之公共利益**目的，其與目的之達成間具**直接及絕對必要關聯**，且賦予人民獲立即司法救濟之機會，始符合憲法比例原則及保障言論自由之意旨。

釋字第 806 號理由書第 13 段

系爭規定……要求街頭藝人須於指定場所解說、操作、示範或表演，**經審查通過後，始取得**……活動**許可證**，其審查內容，有部分係對申請者之表演品質，亦即技藝能力加以審查，從而涉及對於從事藝文活動內容之管制，應適用嚴格審查標準。至涉及時間、地點、方式等無關藝文活動內容管制之部分，則適用前揭中度審查標準審查。

關於事前限制是否構成雙軌雙階理論外之獨立干預類型、如何決定其審查標準的問題，大法官的立場有所浮動。釋字 445 號解釋就本質上屬於「事前禁止」的集遊禁制區，未課予「明顯立即危險」的嚴格要求。與此相對，釋字 744 號對商業廣告的事前審查採取史上最嚴格的審查標準。但是後續的釋字 806 號對高價值藝術表現自由的事前時間、地點、方式限制，卻又

寬鬆審查標準。

回歸雙軌理論決定審查標準[31]。

2. 言論內容中立的管制（時間、地點、方式）→中度審查（J445）

釋字第 806 號理由書第 13 段

……對申請者之表演品質，亦即技藝能力加以審查，從而涉及對於從事藝文活動內容之管制，應適用嚴格審查標準。至**涉及時間、地點、方式等無關藝文活動內容管制之部分，則適用前揭中度審查標準審查**。

3. 針對言論內容的管制（觀點、效果(?)）

(1) 高價值言論：政治、宗教言論→嚴格審查（J445）

113 年憲判字第 5 號理由第 26-28 段

有關國家法令及政策之意見提供及公共討論、對於政府權力行使之監督批評、或對政府機關及公務人員表現之評價及反應等，因具有形成公意、監督施政及實踐民主等重要功能，應受憲法之高度保障。按憲法保障言論自由之主要目的之一，正是要保障人民對於國家權力之異議、反對，而不只是要保障人民對國家之順從、支持。又不論是在歷史及各國實務中，此等質疑或批評公權力之言論，往往會因其表意內容或方式有爭議，或兼具負面影響，而更容易受到國家公權力之不當鎮壓或過度管制，因此也更需要憲法言論自由之保障。……為貫徹自由民主憲政秩序之基本精神及原則，國家對於涉及公共事務言論之內容及觀點，原即應盡可能保持中立，容許各該言論內容或觀點在言論市場中相互論辯、競爭對抗，而不應偏袒一方。**尤其是就直接針對國家機關、政府施政或公務執行等公權力之異議或反對言論，國家更應給予最大之保障**，並就人民表意之語言運用及情緒表達等，予以較大限度之容忍，不應逕自動用刑罰直接壓制此等異議或反對言論。再者，鑑於我國過去威權統治期間，長期以刑罰手段箝制言論，致有人民動輒言論成罪、偶語入獄的慘痛經驗，民主化後之國家對於質疑、批評政府公權力行使之言論，亦宜抱持較寬容之態度，以確保憲法對於言論自由的最大限度保障不致落空。……是本庭就系爭規定所定**侮辱職務罪，應採嚴格標準予以審查**；就侮辱公務員罪部分，因另涉對公務員之侮辱，則採中度標準予以審查。

[31] 憲法法庭 110 年度憲二字第 247 號聲請案蘇慧婕副教授專家諮詢意見書，頁 4。

(2) 中價值言論：商業言論→中度審查（J414、J577、J794）

釋字 794 號[32]理由書第 11 段

憲法第 11 條規定，人民之言論自由應予保障。言論自由，在於保障意見之自由流通，使人民有取得充分資訊及自我實現之機會，包括政治、學術、宗教及商業言論等，並依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則。其中**非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，固兼具意見表達之性質，然尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀，立法者亦得對商業言論為較嚴格之規範**。商品廣告所提供之訊息，其內容須非虛偽不實或不致產生誤導作用，並以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，始受憲法第 11 條言論自由之保障。國家為保障消費者獲得真實而完整之資訊，避免商品廣告或標示內容造成誤導作用，或為增進其他**重要公共利益目的**（如保護國民健康），自得立法採取與上述目的之達成間具有**實質關聯**之手段，限制商品廣告（本院釋字第 414 號、第 577 號及第 744 號解釋參照）。

(3) 低價值言論：猥褻、挑釁言論→低度審查（J407、J617）

釋字第 617 號[33]理由書第 2 段

社會風化之概念，常隨社會發展、風俗變異而有所不同。然其本質上既為各個社會多數人普遍認同之性觀念及行為模式，自應由民意機關以多數判斷特定社會風化是否尚屬社會共通價值而為社會秩序之一部分，始具有充分之民主正當性。**為維持男女生活中之性道德感情與社會風化，立法機關如制定法律加以規範，則釋憲者就立法者關於社會多數共通價值所為之判斷，原則上應予尊重**。惟性言論與性資訊，因閱聽人不同之性認知而可能產生不同之效應……仍應對少數性文化族群依其性道德感情與對社會風化之認知而形諸為性言論表現或性資訊流通者，予以保障。

雙軌理論的預設是**理念市場的意見自由交換**，即如同經濟市場，言論交換的市場原則上也應維持自由開放，包括放任錯誤言論，因為「真理越辯越明」。因

[32] 本號解釋涉及禁止菸商的顯名贊助行為，其認為系爭菸害防制法規定係「避免菸品業者假贊助之名，而達廣告或促銷菸品之實，同時產生破壞菸品去正常化之負面效果」（理由書第 16 段），手段目的具實質關聯。然而，贊助行為可能表達對所贊助對象代表之價值（言論內容）的贊同，未必無關公意形成，乃本號解釋忽略的面向。

[33] 至於本號解釋沿襲釋字 407 對猥褻言論的定義，及其著名的對系爭刑法第 235 條散布猥褻物罪所為區分「硬蕊」、「軟蕊」之合憲性解釋，另參理由書第 3、4 段。

此，國家基於其對特定思想、觀點或訊息的偏好所為的言論管制（觀點歧視），就被視為對言論市場的**扭曲**，故應從嚴審查；僅涉言論時間、地點及方式的限制（內容中立）則因無扭曲市場的風險，而得從寬審查。另一方面，此等管制也反映國家對**言論交換市場及思想論辯力量的不完全信任**，即不相信表意人的理性說服及受眾的理性判斷會保證真理終將勝出。法院對低價值言論降低審查標準則在一定限度肯認此種不信任。由此觀之，雙／三階理論與雙軌理論所預設的國家言論內容中立性原則毋寧存在邏輯上的衝突。

四、 重要實務見解

（一）審查標準的確立：釋字 445

釋字第 445 號理由書第 8、10、11 段

於事前審查集會、遊行之申請時，苟著**重於時間、地點及方式等形式要件**，以法律為明確之規定，**不涉及集會、遊行之目的或內容**者，則於表現自由之訴求不致有所侵害。主管機關為維護交通安全或社會安寧等重要公益，亦得於**事前採行必要措施**，妥為因應。……**禁制區**之劃定在維護國家元首、憲法機關及審判機關之功能、對外交通之順暢及重要軍事設施之安全，故除經主管機關核准者外，不得在此範圍舉行集會、遊行，乃為**維持社會秩序或增進公共利益所必要**，同條就禁制地區及其週邊範圍之規定亦甚明確，自屬符合法律明確性原則，並無牴觸憲法情事。言論地點→重要公益＋事前必要措施

第一款：「違反第四條、第六條、第十條之規定者。」按第四條規定「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」所謂「**主張共產主義或分裂國土**」**原係政治主張之一種，以之為不許可集會、遊行之要件，即係賦予主管機關審查言論本身的職權**，直接限制表現自由之基本權。……倘於申請集會、遊行之始，僅有此主張而**於社會秩序、公共利益並無明顯而立即危害之事實**，即不予許可或逕行撤銷許可，則無異僅因主張共產主義或分裂國土，即禁止集會、遊行，不僅干預集會、遊行參與者之政治上意見表達之自由，且**逾越憲法第二十三條所定之必要性**。（政治性）言論觀點→明顯立即危險

第二款：「有事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益之虞者。」……為確保社會安寧秩序，憲法所保障之集會、遊行，必須以和平方式為之，若逾此限度，法律始得加以限制，惟法律限制之要件，應明確而具體。本款規定所稱「危害國家安全、社會秩序或公共利益」均為概括條款，有欠具體明確，委諸主管之警察機關，於短期間內判斷有此事實足認有妨害上開法益之虞，由於室外集會、遊行難免對他人之自由、社會秩序或公共利益有不利影響，主管機關**對此尚未達到明顯而立即危險之事實若為實質審查，僅憑將來有發生之可**

能，即以之為准否之依據，易生干預人民集會自由之情事，與集會遊行法第十一條限制主管機關裁量權之立法意旨亦有未符。是本款規定列為事前審查之許可要件，即係**侵害憲法所保障集會自由之權利**。溝通效果→明顯立即危險

（二）消極言論自由干預

釋字第 577 號理由書第 2、3 段

商品標示為提供商品客觀資訊之方式，為商業言論之一種，有助於消費大眾之合理經濟抉擇。……惟國家為保障消費者獲得真實而完整之資訊、避免商品標示內容造成誤導作用、或為增進其他**重大公益目的**，自得立法採取與目的達成有**實質關聯**之手段，明定業者應提供與商品有關聯性之重要商品資訊。

國家課予菸品業者於其商品標示中提供重要客觀事實資訊之義務，係屬對菸品業者不標示特定商品資訊之**不表意自由之限制**。惟此項標示義務，有助於消費者對菸品正確了解。且告知菸品中特定成分含量之多寡，亦能使消費者意識並警覺吸菸行為可能造成之危害，**促其審慎判斷**，作為是否購買之參考，明顯有助於**維護國民健康**目的之達成；相較課予菸品業者標示義務，責由各機關學校辦理菸害防制教育，固屬較小侵害手段，但於目的之達成，尚非屬相同有效手段，故課予標示義務並未違反必要原則；又衡諸提供消費者必要商品資訊與維護國民健康之重大公共利益，課予菸品業者標示義務，**並非強制菸品業者提供個人資料或表達支持特定思想之主張，亦非要求其提供營業秘密，而僅係要求其提供能輕易獲得之商品成分客觀資訊**，尚非過當。

釋字第 656 號理由書第 2、3 段

系爭規定既包含以判決命加害人**登報道歉**，即涉及憲法第十一條言論自由所保障之不表意自由。國家對不表意自由，雖非不得依法限制之，惟**因不表意之理由多端，其涉及道德、倫理、正義、良心、信仰等內心之信念與價值者，攸關人民內在精神活動及自主決定權**，乃個人主體性維護及人格自由完整發展所不可或缺，亦與維護人性尊嚴關係密切（本院釋字第六０三號解釋參照）。

查系爭規定旨在維護被害人名譽，以保障被害人之人格權。鑒於名譽權遭侵害之個案情狀不一，金錢賠償未必能填補或回復，因而授權法院決定適當處分，目的洵屬正當。而法院在原告聲明之範圍內，權衡侵害名譽情節之輕重、當事人身分及加害人之經濟狀況等情形，認為諸如在合理範圍內由加害人負擔費用刊載澄清事實之聲明、登載被害人判決勝訴之啟事或將判決書全部或一部登報等手段，**仍不足以回復被害人之名譽者**，法院以判決命加害人公開道歉，作為回復名譽之適當處分，尚未逾越必要之程度。惟如要求加害人公開道歉，**涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即屬逾越回復名譽之必要程度，而**

過度限制人民之不表意自由。依據上開解釋意旨，系爭規定即與憲法維護人性尊嚴與尊重人格自由發展之意旨無違。

111 年憲判字第 2 號理由第 9、12 段

國家禁止人民積極表意，人民尚得保持沉默。**強制公開道歉之手段係更進一步禁止沉默、強制表態，以致人民必須發表自我否定之言論，其對言論自由之干預強度顯然更高**。又容許國家得強制人民為特定內容之表意，甚至同時指定表意時間、地點及方式等，必然**涉及言論內容之管制**。又強制公開道歉係直接干預人民**是否及如何表達其意見或價值立場之自主決定，而非僅涉及客觀事實陳述之表意，顯屬對高價值言論內容之干預**。又除自然人外，法人亦得為憲法言論自由之權利主體（司法院釋字第 577 號及第 794 號解釋參照）。不論加害人是自然人或法人，強制公開道歉均會干預其自主決定是否及如何表意之言論自由。於加害人為新聞媒體（包括機構或個人媒體等組織型態）時，甚還可能干預其新聞自由，從而影響新聞媒體所擔負之健全民主、公共思辨等重要功能。是系爭規定應受**嚴格審查**，其立法目的須係為追求特別重要公共利益，其手段須係為達成其立法目的所不可或缺、且別無較小侵害之替代手段，始符合憲法保障人民言論自由之意旨。

按公開刊載法院判決被害人勝訴之啟事或判決書之方式，即可讓社會大眾知悉法院已認定被告有妨害他人名譽之行為，而有助於填補被害人名譽所受之損害，且不至於侵害被告之不表意自由。法院於審判過程或判決理由中，亦可鼓勵或期許加害人向被害人道歉。又加害人如自認有錯，仍可真誠向被害人道歉，不待法院之強制。反之，法院如以判決命加害人向被害人道歉，並得由被害人逕以加害人之名義刊載道歉啟事，再由加害人負擔費用（強制執行法第 127 條第 1 項規定參照），實無異於容許被害人以加害人名義，逕自違反加害人自主之言論。對加害人而言，非出於本人真意之道歉實非道歉，而是違反本意之被道歉；對被害人而言，此等心口不一之道歉，是否有真正填補損害之正面功能，亦有疑問。是法院以判決命加害人公開道歉，不論加害人為自然人或法人，縱未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事，亦顯非不可或缺之最小侵害手段，而與憲法保障人民言論自由之意旨有違。

（三）言論溝通效果的限制：妨害名譽罪

1. 妨害名譽罪解析

刑法第 309 條

I **公然侮辱**人者，處拘役或九千元以下罰金。
II 以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

刑法第 310 條

I 意圖散布於眾，而指摘或傳述**足以毀損他人名譽**之事者，為**誹謗罪**，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。
II 散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。
III 對於所誹謗之事，**能證明其為真實**者，不罰真實性抗辯。但**涉於私德而與公共利益無關**者，不在此限不實或真實均處罰。

刑法第 311 條

I 以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：

一、因自衛、自辯或保護合法之利益者。
二、公務員因職務而報告者。
三、對於可受公評之事，而為適當之評論者。
四、對於中央及地方之會議或法院或公眾集會之記事，而為適當之載述者。

2. 112 年憲判字第 8 號誹謗罪案（二）

(1) 審查原則

A. 基本權衝突：言論自由 vs.名譽權→利益衡量

B. 特別考量：「**公益論辯貢獻度**」

a. 公共事務→高

b. 私人事務、單純事實陳述→低

c. 真實查證義務作為言論自由保障的界線

> 理由第 53 段
>
> 於名譽權與言論自由間為個案利益衡量時，應特別考量言論對公益論辯之貢獻度。一般而言，言論內容涉及公共事務而與公共利益有關者，通常有助於民主社會之公意形成、公共事務之認知、溝通與討論，其對公益論辯之貢獻度較高；而言論內容涉及私人生活領域之事務者，其對公益論辯之貢獻度則較低。惟事實性言論因具資訊提供性質，且客觀上有真偽、對錯之分，如表意人所為事實性言論，並未提供佐證依據，僅屬單純宣稱者，即使言論內容涉及公共事務而與公共利益有關，因言論接收者難以判斷其可信度，此種事實性言論之公益論辯貢獻度亦不高。

(2) 適當、必要（無論證）

(3) 衡平性：310III 作為言論自由與名譽權均衡之最後一道總括性利益衡量防線

A. 310III 但書純涉私德無關公益

理由第 67 段

所謂「私德」，往往涉及個人生活習性、修養、價值觀與人格特質等，且與個人私生活之經營方式密不可分，乃屬憲法第 22 條所保障之隱私權範圍，甚至可能觸及人性尊嚴之核心領域。此類涉及個人私德之事之言論指述，常藉助於上述**兼具事實性與負面評價性意涵**之用語、語句或表意方式，**本即難以證明其真偽**。然如仍欲於刑事訴訟程序上辨其真偽，無論由檢察官或表意人負舉證責任，**於證據調查程序中，勢必須介入被指述者隱私權領域**，甚至迫使其揭露隱私於眾，或使被指述者不得不就自身隱私事項與表意人為公開辯駁。此等情形下，被指述者之隱私權將遭受侵犯。因此，如立法者欲使涉及私德之言論指述，得享有真實性抗辯者，即須具備限制被指述者隱私權之正當理據，**事涉公共利益之理由**即屬之（如高階政府官員或政治人物與犯罪嫌疑人或被告之飲宴、交際等，攸關人民對其之信任）。反之，如涉及私德之誹謗言論，與公共利益無關時，客觀上實欠缺獨厚表意人之言論自由，而置被害人之名譽權及隱私權保護於不顧之正當理由。從而，此種情形下，**表意人言論自由自應完全退讓於被指述者名譽權與隱私權之保護**。

「私德」概念如何界定？是否存在「無涉私德亦無關公益」的誹謗言論、此時應如何適用 310III？參酌本判決論述脈絡，所謂私德言論應該限於「內容涉及受隱私權保障之空間或領域」的言論，而不包含內容涉及「合理隱私期待範圍外之社會生活領域」的言論。從而，非受隱私權保障的「無涉私德亦無關公益」之誹謗言論，仍應適用 310III 前段的不罰要件；換言之，為避免解釋漏洞，「有關公益」不應認定為 310III 前段的適用前提[34]。

[34] 蘇慧婕，言論自由的民主工具化——憲法法庭 112 年憲判字第 8 號判決評析，裁判時報，142 期，頁 10-11，2024 年。蘇老師另批評 112 憲判 8 對刑法 310III 但書的見解混淆名譽權和隱私權的保障範圍，更忽視真實言論的自主價值。就後者而言，112 憲判 8 判決贊同刑法第 310 條第 3 項但書的「隱私權絕對優先」判斷，意味著大法官認為揭露隱私言論的表意人自主價值可以忽略不計。在 2023 年 5 月發生的臺灣#MeToo 運動中，112 憲判 8 判決這種過度偏重民主功能、不當輕忽自主與真理功能的一貫立場傾向，就清楚顯現出論證不當之處：依據被宣告合憲的刑法第

B. 刑 310III 前段真實性抗辯

所謂「**言論真實性」要求，非可逕解為係要求言論內容之客觀、絕對真實性**。事實性言論，尤其媒體就公共領域相關新聞、事件之追蹤、報導，於報導時，往往尚不存在全知視角下之絕對真實性，於報導之事件尚發展或進行中時尤然；且報導主題涉及政治、經濟與社會重大事件時，牽涉之人、事、物範圍愈大，即愈難於揭露、報導該事件之初，求其所謂客觀、絕對真實性。如認包括以媒體報導方式所呈現之誹謗言論，表意人僅能以言論內容之客觀、絕對真實性為抗辯，始得免受刑罰，不啻令媒體僅能於事過境遷，甚至已有司法定論時，始得為相關事件之報導。如此一來，**恐將大幅度壓縮報導性言論自由之空間，並斲傷言論自由於民主社會所應發揮之滿足人民知的權利，及監督政府與公共事務等重要功能**。是此等法律解釋方式，於表意人言論自由與被指述者名譽權保護間之利益衡量，顯有失衡之慮。

另一方面，於民主社會中，各種涉及公共利益議題之事實性言論，乃人民據以為相關公共事務之認知與評價之基礎，其如於**結合電子網路之傳播媒體上所為時，尤因其無遠弗屆之傳播力，以及無時間限制之反覆傳播可能性，對閱聽群眾之影響力極大，且閱聽者往往無法自行查證、辨其真偽**網路通訊條件→受眾查證障礙。因此，正是基於維護負有多重使命之言論自由，當代民主社會之事實性資訊提供者，無論是媒體或一般人，均應負有一定程度之**真實查證義務**，而不得恣意散播不實或真假難辨之資訊於眾，助長假新聞、假訊息肆意流竄，致顛覆自由言論市場之事實根基。況基於明知或重大輕率之惡意而散播假新聞或假訊息，本不受憲法言論自由之保障。於言論內容有毀損他人名譽之虞時，表意人就其言論內容之可信性，更應承擔一定程度之真實查證義務，以避免侵害他人名譽權。

……於事實探求程序中所得出之**相對真實性**，即**表意人經由合理查證程序，依所取得之證據資料，客觀上可合理相信其言論內容為真實**者，即屬合於系爭規定三前段所定不予處罰之要件事前合理查證程序＋客觀合理真實信念。即使表意人於合理查證程序所取得之證據資料實非真正，卻成為表意人所為誹謗言論基礎之情形，只要表意人就該不實證據資料之引用，並**非基於明知或重大輕率之惡意**，仍得因其客觀上已踐行合理查證程序，而有系爭規

310 條第 3 項但書規定，被害人揭露非公共人物在私密空間裡的性騷擾或性侵害行為，即便指控內容為真，也會一律受到刑法第 310 條第 3 項但書的處罰。參頁 22-23。

定三前段規定之適用。

至於表意人事前查證程序是否充分且合理之**判斷**，應再次衡酌表意人言論自由，與誹謗言論所指述者之名譽權間之衡平關係。對此，應**依個案情形**，具體考量表意人指摘或傳述誹謗言論之方式、散布力與影響力、所為言論對被指述者名譽之毀損方式、程度與影響範圍，及該言論對公益論辯之貢獻度。從而，於**傳播媒體**（包括大眾傳播媒體、社群媒體與自媒體等）上所為誹謗言論，因其**散布力與影響力均極強大**，誹謗言論一經發表，並被閱聽者轉貼、轉載後，往往可**對被指述者之名譽造成難以挽救之毀損**，是表意人所應踐行之事前查證程序，較諸一般人日常生活中以言詞所為口耳間傳播之誹謗言論，自應更為周密且嚴謹。另一方面，基於言論自由對民主社會所具有之多種重要功能，**言論內容對公益論辯之貢獻度愈高**者，例如對滿足人民知的權利，及監督政府與公共事務之助益程度愈高，表意人固非得免於事前查證義務，惟於表意人不具明知或重大輕率之惡意之前提下，其容錯空間相對而言亦應愈大，以維護事實性言論之合理發表空間，**避免產生寒蟬效應**。

【比較】釋字第 509 號理由書第 2 段

刑法第三百十條第三項前段規定：「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」，係以指摘或傳述足以毀損他人名譽事項之行為人，其言論內容與事實相符者為不罰之條件，並**非謂行為人必須自行證明其言論內容確屬真實**，始能免於刑責。惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當**理由確信其為真實**者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。就此而言，刑法第三百十條第三項與憲法保障言論自由之旨趣並無牴觸。

因為 112 憲判 8 認定單純事實陳述的公益論辯貢獻度較低，而且網路言論可輕易去脈絡、再連結的傳播方式會造成受眾的查證障礙，所以在發表事實陳述者的不罰要件上，就提出比釋字 509「相當真實確信」**更為嚴格**的「事前合理查證程序」加上「客觀合理真實信念」的雙重要件，**實質變更**該號解釋的立場[35]。

[35] 蘇慧婕，註 34，頁 13、20。蘇老師另批評 112 憲判 8 提高真實查證的門檻，使未損害公共利

3. 113 年憲判字第 3 號公然侮辱罪案

(1) 審查原則

理由第 32 段

侮辱性言論因包含可能減損他人聲望、冒犯他人感受、貶抑他人人格之表意成分，而有其負面影響。然此種言論亦涉及一人對他人之評價，仍可能具有言論市場之**溝通思辯及輿論批評功能**。又**評價不僅常屬言人人殊之價值判斷，也往往涉及言論自由之保障核心：個人價值立場之表達**。再者，侮辱性言論之表意脈絡及**所涉事務領域相當複雜、多元**，除可能同時具有政治、宗教、學術、文學、藝術等高價值言論之性質外（例如：對發動戰爭者之攻擊、貶抑或詛咒，或諷刺嘲弄知名公眾人物之漫畫、小說等），亦可能兼有抒發情感或表達風格（例如不同評價語言之選擇及使用）之表現自我功能。故**不應僅因表意人使用一般認屬髒話之特定用語，或其言論對他人具有冒犯性，因此一律認定侮辱性言論僅為無價值或低價值之言論**，而當然、完全失去憲法言論自由之保障。法院於適用系爭規定時，**仍應權衡侮辱性言論對名譽權之影響及其可能兼具之言論價值**。

基於**刑法最後手段性原則**，本庭於審查以刑法制裁言論之系爭規定時，尤應權衡其刑罰目的所追求之正面效益（如名譽權之保障），是否明顯大於其限制言論自由所致之損害，以避免檢察機關或法院須就無關公益之私人爭執，扮演語言警察之角色，而過度干預人民間之自由溝通及論辯。

113 憲判 3 從妨害名譽言論此一言論類型的本質特徵——既不涉及特定言論觀點、亦不對應特定事務領域——出發，首次正面闡述了妨害名譽言論限制無法直接套用雙軌、雙階理論的理由：旨在防免觀點歧視的雙軌理論，以及依據言論內容所涉事務領域去擇定審查標準的雙階理論，無法完全套用到不指涉特定觀點，又具有跨事務領域性質的妨害名譽言論，故而限制妨害名譽言論的法律也就無法依據雙階理論去適用單一特定的審查標準[36]。

益或他人權利之錯誤事實資訊失去言論自由的保障，但此等**無害謊言也可能有表意人自我實現功能**，本判決忽視此言論自由的自主功能；此外，合理查證程序**要求表意人為網路傳播的特性及整體通訊環境的複雜化負責**，對表意人過苛、可能引發寒蟬效應，且此等標準實務上也難以操作。參頁 19-21。

[36] 蘇慧婕，非觀點歧視之言論內容限制的審查標準——憲法法庭 113 年憲判字第 3 號判決評析，台灣法律人，40 期，頁 147、149，2025 年。

(2) 目的審查：名譽權

A. 社會名譽（V）

理由第 40 段

一人對他人之公然侮辱言論是否足以損害其真實之社會名譽，仍須**依其表意脈絡個案認定**之。如侮辱性言論**僅影響他人社會名譽中之虛名**，或對真實社會名譽之可能**損害尚非明顯、重大，而仍可能透過言論市場消除或對抗此等侮辱性言論**，即**未必須逕自動用刑法予以處罰**。然如一人之侮辱性言論已足以對他人之真實社會名譽造成損害，立法者為保障人民之社會名譽，以系爭規定處罰此等公然侮辱言論，於此範圍內，其立法目的自屬正當。

B. 名譽感情（X）

理由第 42 段

名譽感情係以個人主觀感受為準，既無從探究，又無從驗證……如認個人主觀感受之名譽感情得逕為公然侮辱罪保障之法益，則將難以預見或確認侮辱之可能文義範圍。蓋一人耳中之聒聒噪音，亦可能為他人沉浸之悅耳音樂。聽聞同樣之粗鄙咒罵或刻薄酸語，有人暴跳如雷，有人一笑置之。如認名譽感情得為系爭規定之保護法益，則任何隻字片語之評價語言，因對不同人或可能產生不同之冒犯效果，以致不知何時何地將會一語成罪。是系爭規定立法目的所保障之名譽權內涵應不包括名譽感情。

C. 名譽人格（V）

理由第 45 段

個人受他人平等對待及尊重之主體地位，不僅關係個人之人格發展，也有助於社會共同生活之和平、協調、順暢，而有其公益性。又對他人平等主體地位之侮辱，如果同時涉及**結構性強勢對弱勢群體**（例如種族、性別、性傾向、身心障礙等）身分或資格之貶抑，除顯示表意人對該群體及其成員之敵意或偏見外，更會影響各該弱勢群體及其成員在社會結構地位及相互權力關係之實質平等，而有其**負面的社會連漪效應，已不只是個人私益受損之問題**。是故意貶損他人人格之公然侮辱言論，確有可能貶抑他人之平等主體地位，而對他人之人格權造成重大損害。

(3) 手段審查：合憲性限縮解釋。

由於系爭規定所處罰之公然侮辱行為，其文義所及範圍或適用結果，或因欠缺穩定認定標準而有過度擴張外溢之虞，或可能過度干預個人使用語言習慣及道德修養，或可能處罰及於兼具輿論功能之負面評價言論，而有對言論自由過度限制之風險。為兼顧憲法對言論自由之保障，系爭規定所處罰之公然侮辱行為，應指：依個案之表意脈絡，表意人故意發表公然貶損他人名譽之言論，**已逾越一般人可合理忍受之範圍**；經權衡該言論對他人名譽權之影響，及該言論依其表意脈絡是否有益於公共事務之思辯，或屬文學、藝術之表現形式，或具學術、專業領域等**正面價值，於個案足認他人之名譽權應優先於表意人之言論自由**而受保障者。

先就**表意脈絡**而言，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽之意涵即認定之，而應就其表意脈絡整體觀察評價。如脫離表意脈絡，僅因言詞文字之用語負面、粗鄙，即一律處以公然侮辱罪，恐使系爭規定成為髒話罪。具體言之，除應參照其前後語言、文句情境及其文化脈絡予以理解外，亦應考量表意人之個人條件（如年齡、性別、教育、職業、社會地位等）、被害人之處境（如被害人是否屬於結構性弱勢群體之成員等）、表意人與被害人之關係及事件情狀（如無端謾罵、涉及私人恩怨之互罵或對公共事務之評論）等因素，而為綜合評價。例如被害人自行引發爭端或自願加入爭端，致表意人以負面語言予以回擊，尚屬一般人之常見反應，仍應從寬容忍此等回應言論。又如被害人係**自願表意或參與活動而成為他人評論之對象**（例如為尋求網路聲量而表意之自媒體或大眾媒體及其人員，或受邀參與媒體節目、活動者等），致遭受眾人之負面評價，可認係自招風險，而應自行承擔。反之，具**言論市場優勢地位**之網紅、自媒體經營者或公眾人物透過網路或傳媒，故意公開羞辱他人，由於此等言論對他人之社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，即應承擔較大之言論責任。

又就對他人社會名譽或名譽人格之影響，是否**已逾一般人可合理忍受之範圍**而言，按個人在日常人際關係中，難免會因自己言行而受到他人之月旦品評，此乃社會生活之常態。一人對他人之負面語言或文字評論，縱會造成他人之一時不悅，然如其冒犯及影響程度輕微，則尚難逕認已逾一般人可合理忍受之範圍。……如一人對他人之負面評價，依社會共同生活之一般通念，確會對他人造成精神上痛苦，並足以對其心理狀態或生活關係造成不利影響，甚至自我否定其人格尊嚴者，即已逾一般人可合理忍受之限度，而得以刑法處罰之。例如透過

網路發表或以電子通訊方式散佈之公然侮辱言論，因較具有**持續性、累積性或擴散性**，其可能損害即常逾一般人可合理忍受之範圍。

再者，就負面評價言論之可能**價值**而言，一人就公共事務議題發表涉及他人之負面評價，縱可能造成該他人或該議題相關人士之精神上不悅，然既屬公共事務議題，則此等負面評價仍可能兼具促進公共思辯之輿論功能。又如以文學或藝術形式表現之言論（例如嘲諷文學、漫畫或歌曲等），縱包括貶抑他人之表意成分，仍不失其文學或藝術價值。至一人針對他人在職業上之言行（例如工作表現、著述演講或表演之內容及品質等），發表負面評價，亦可能具有評價他人表現之學術或各該專業等正面價值，而非全然無價值之言論。是就此等言論，亦應依其表意脈絡，考量其是否**有益於公共事務之思辯，或屬文學、藝術之表現形式，或具學術、專業領域等正面價值**，而不宜逕以公然侮辱罪相繩[37]。

陸、 平等權

一、 保障範圍

（一）權利特殊性：等者等之，不等者不等之→群體之間平等的自由權保障

釋字第 593 號理由書第 4 段

按等者等之，不等者不等之，為憲法平等原則之基本意涵。是如對相同事物為差別待遇而無正當理由，或對於不同事物未為合理之差別待遇，均屬違反平等原則。

1. 等者等之：性質相同的**群體**，享有相同程度的**自由權**保障
2. 不等者不等之：性質不同的**群體**，**依其性質差異**享有不同程度的**自由權**保障

（二）權利內容：實質平等

釋字第 485 號理由書第 1 段

憲法第七條平等原則並非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上

[37] 因此，不只是貶抑用語未必具有侮辱意涵，具有侮辱意涵的言論未必會導致名譽損害結果，即便言論確實導致了他人名譽權的損害，言論自由也未必都應該向名譽權退讓。蘇慧婕，註 36，頁 148。

地位之實質平等，立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之區別對待。

1. 不等者不等之：在具體個案脈絡下（→規範目的），依個人本質差異，採取相應（合理）的差別對待。

2. 等者／不等者→**規範目的**的確定

(1) 等者：群體差異與規範目的無關→不當連結：「歧視」禁止、「恣意」禁止

(2) 不等者：群體差異與規範目的有關

（三）附論：實質平等的歧義[38]

釋字第 571 號林子儀大法官協同意見書

本院習稱之「實質平等」，其與「等者等之，不等者不等之」平等公式思考如出一轍。此亦為美國、德國、日本等國法院在實際解釋適用憲法所保障的平等權時所運用的公式，然而單憑「等者等之，不等者不等之」公式卻無從指引我們：得否將人分類？如何將人分類？應選擇何人與何人相比？兩者間就何種事項而言應屬相同（或不同）？又何謂相同待遇（或差別待遇）？換言之，「等者等之」公式本身不包涵任何實質價值在內，故也無法幫助我們進行上述諸種實質價值判斷，其毋寧僅是一形式、空洞且同義反覆的說法，因此與所謂「實質平等」之用語並不相稱。**就其概念、內涵缺乏實質價值而言，毋寧亦屬於一種「形式平等」。**

1. 實質平等觀要素

(1) 特定弱勢族群或團體人民之保障（「分散又隔離的少數」）

A. 不可改變之不利特徵

B. 政治結構或程序上的弱勢地位

C. 對該分類存有歷史或社會性的歧視

(2) 容許或要求國家的積極保障，而不僅是消極的恣意歧視禁止

[38] 參黃昭元，平等權與自由權競合案件之審查——從釋字第六四九號解釋談起，法學新論，7 期，2009 年。欲知形式平等與實質平等兩種平等觀的前因後果，務必另參黃昭元，從平等理論的演進檢討實質平等觀在憲法適用上的難題，收於：憲法解釋之理論與實務（第九輯），頁 271-312，2017 年。

2. 事實不平等的類型

(1) 表面上中立的國家公權力，其現實適用結果造成事實上之系統性歧視或差別影響

(2) 過去的國家歧視行為雖已結束，但其效應延續至今

(3) 私人所為的社會性歧視，因而對某些群體造成長期、固定性的不利影響

(4) 先天或後天所致，個人或結構性的事實上不利地位

→皆能解釋成「規範上應區分而未區分」，也早已為現代憲政的平等保障所涵蓋，與「等者等之，不等者不等之」的形式平等公式相容。

二、 權利干預

（一）國家行為：（未為）差別待遇／歧視

1. 法律上（*de jure*）的差別待遇＝直接歧視／差別影響歧視

2. 事實上（*de facto*）的差別待遇＝間接歧視／差別對待歧視

法規範本身在**表面上中立**（facially neutral），並未使用某項分類（如種族），然**實際適用結果，會對某些群體造成系統性的不利差別待遇**[39]。

> 釋字第 666 號理由書第 3 段
>
> 系爭規定（按：社維法罰娼不罰嫖）既不認性交易中支付對價之一方有可非難，卻處罰性交易圖利之一方，**鑑諸性交易圖利之一方多為女性之現況，此無異幾僅針對參與性交易之女性而為管制處罰，尤以部分迫於社會經濟弱勢而從事性交易之女性，往往因系爭規定受處罰，致其業已窘困之處境更為不利**。系爭規定以主觀上有無意圖得利，作為是否處罰之差別待遇標準，與上述立法目的間顯然欠缺實質關聯，自與憲法第七條之平等原則有違[40]。

[39] 釋字第 760 號黃昭元大法官協同意見書，第 4 段。

[40] 更直接、完整的論述可參同號解釋許宗力大法官協同意見書：認定間接之性別差別待遇存在與否，並不等於決斷該規範係合憲或違憲，毋寧是要將**隱藏在性別中立規範下，具有憲法重要性的規範現實揭露出來，一併考量**。本件解釋系爭規定的制裁對象是「意圖營利而與人姦宿者」，雖未明文以性別為差別待遇基準，為一表面性別中立的立法例，但在我國的脈絡中，對性工作者的管制與處罰卻帶有非常濃厚的性別意涵，是最**典型的事實上性別差別待遇**案例……或有謂性工作者乃常業從事性交易，而顧客僅偶一為之，因此前者較易危害國民健康，自較諸後者可罰。但上述說法充其量只是一種臆測，實則有相當比例的尋芳客慣常地尋求性服務。此外，正因性工作者乃常業性地從事性交易，因此更有可能謹慎採取安全性行為，以保護自己與

釋字第 791 號理由書第 43 段

系爭規定一及二（按：通姦罪及對通姦配偶單獨撤告規定）雖就字面觀察，並未因受規範者之性別而異其效力，屬**性別中立之規定**，且目前實務上通姦及相姦罪之成立，以男女共犯為必要，其男女人數理應相當，惟其**長年實際適用結果，女性受判決有罪之總人數明顯多過男性**。是系爭規定二之實際適用結果致受系爭規定一刑事處罰者，長期以來，呈現性別分布失衡之現象，顯現女性於通姦及相姦罪之訴追、審理過程中，實居於較為不利之處境，足見系爭規定一及二之長期存在，與**憲法增修條文第 10 條第 6 項促進兩性地位實質平等**之要求，是否相符，確有疑義。惟系爭規定一及二既如前述已經宣告違憲失效，上述性別失衡之問題將不復存在，併此指明。

113 年憲判字第 6 號理由第 30 段

系爭規定一在**形式上雖未排除女性之應考資格**，並依男女平均身高之差異而設定不同最低身高限制標準，惟並未慮及在各該身高限制下所排除之性別群體比例是否相當，致使系爭規定一**對女性形成較男性更為嚴格之身高限制，使實際上女性符合應考消防警察人員資格之人數，遠少於男性得以應考之人數**。依關係機關統計數據，截至 111 年我國消防人力男性占比為 88%，女性為 12%，系爭規定一之適用結果無疑更**加深消防警察人員男女人數之懸殊比例，亦導致整體警消工作環境與文化，持續依男性之需求而為配置與定義，不利於女性人力之參與**。

三、 干預的正當化[41]

112 年憲判字第 18 號理由第 16 段

憲法平等權之保障，並不當然禁止國家為差別待遇；法規範所為差別待遇，是否符合平等權保障之要求，應視該差別待遇之目的是否合憲，及其所採取之分

顧客的健康。如果本案屬於適用合理審查標準的差別待遇類型，立法者對性工作者較其顧客，更易影響國民健康的推測，或許尚可接受，但**在中度審查之下，則顯得率斷、欠缺依據**，終難逃違憲的命運。最重要的是，國家單獨非難女性性工作者，對男性顧客略而不論的規定，乃在對性工作者表達直接道德譴責之餘，進一步反映了**對兩性的雙重道德標準**。……同樣是參與性交易，女性性工作者遭到社會放逐，男性客戶則蒙社會寬許：「娼」是一種身份，是社會的邊緣人，帶著永難洗刷的污名；但「嫖」卻只是一種男人常做、無傷大雅的行為，在片刻的邂逅之後，旋即回復為受人尊敬的社會成員。……系爭規定不斷強化對女性有害的刻板印象，而**以國家以公權力複製此種刻板印象本身就構成一種性別歧視**，不僅違反憲法保障性別平等之意旨，也違反消除對婦女一切形式歧視公約之精神。

[41] 僅說明實體合憲要件。

類與規範目的之達成間，是否存有一定程度之關聯性而定。

（一）審查層次

1. 分類標準是否合憲：目的合憲、分類標準與目的間關聯性、分類標準精確（無「涵蓋過寬或涵蓋過窄」）

2. 差別待遇程度是否過度（類似自由權限制之審查）

（二）審查標準

釋字第 802 號理由書第 9 段

法規範所採取之分類如未涉及**可疑分類**，且其差別待遇並不涉及**攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利**，本院自得採寬鬆標準予以審查（本院釋字第 768 號及第 794 號解釋參照）。如其立法目的係為追求正當公共利益，且其分類與目的之達成間有合理關聯，即與憲法第 7 條平等權保障無違。

1. 分類標準：嫌疑分類→從嚴審查

釋字第 794 號理由書第 18 段

法規範如以種族、性別、性傾向等為分類，因此等分類往往**涉及難以改變之個人特徵，或屬受有各種事實上或法律上之排斥或歧視者，或為社會上孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢**，本院對於此等分類，應加強審查，而適用嚴格或較為嚴格之審查標準，以判斷其合憲性（本院釋字第 748 號解釋參照）。

111 年憲判字第 4 號理由第 35 段

法規範如採**種族分類**而有差別待遇，或其差別待遇涉及攸關個人人格發展及人性尊嚴之重要基本權利，本庭應加強審查，而適用**嚴格標準**，以判斷其合憲性。

113 年憲判字第 6 號理由第 22 段

法規範如以**性別**為差別待遇之標準者，因性別屬個人與生俱來難以改變之特徵，本庭應適用**中度標準審查**之，其立法目的須為追求憲法上之重要公共利益，其所採取之分類與規範目的之達成間，須存有實質關聯性，始與憲法保障平等權之意旨無違（司法院釋字第 807 號解釋及本庭 112 年憲判字第 1 號判決參照）。

釋字第 748 號理由書第 15 段

性傾向屬難以改變之個人特徵（immutable characteristics）……在我國，同性性傾向者過去因未能見容於社會傳統及習俗，致長期受禁錮於暗櫃內，受有各種事實上或法律上之排斥或歧視；又同性性傾向者因人口結構因素，為社會上孤立隔絕之少數，並因受刻板印象之影響，久為政治上之弱勢，難期經由一般民主程序扭轉其法律上劣勢地位。是以性傾向作為分類標準所為之差別待遇，應適用**較為嚴格之審查標準**，以判斷其合憲性，除其目的須為追求重要公共利益外，其手段與目的之達成間並須具有實質關聯，始符合憲法第 7 條保障平等權之意旨。

2. 自由權重要性：重要基本權的實質限制→從嚴審查

釋字第 626 號理由書第 5 段

系爭招生簡章規定以**色盲**為差別待遇之分類標準，使色盲之考生無從取得入學資格，是否侵害人民接受教育之公平機會，而違反平等權保障之問題，鑑於色盲**非屬人力所得控制之生理缺陷**，且此一差別對待**涉及平等接受教育之機會**，為憲法明文保障之事項，而教育對於個人日後工作之選擇、生涯之規劃及人格之健全發展影響深遠，甚至與社會地位及國家資源之分配息息相關，系爭規定自應受**較為嚴格之審查**。故系爭招生簡章之規定是否違反平等權之保障，應視其所欲達成之目的是否屬重要公共利益，且所採取分類標準及差別待遇之手段與目的之達成是否具有實質關聯而定。

釋字第 760 號理由書第 5 段

鑑於**應考試服公職權為廣義之參政權**，涉及人民參與國家意思之形成及公務之執行，與公共生活秩序之形塑密切相關，對此權利所為之差別待遇，原則上應受**較嚴格之審查**，除其目的須為追求重要公益外，所採差別待遇與目的之達成間亦須有實質關聯，始與憲法保障平等權之意旨相符。

3. 所涉事務領域：立法、行政機關裁量→寬鬆審查

釋字第 750 號理由書第 13 段

此等差別待遇涉及牙醫師技能及醫療服務品質，故**較適合由擁有醫療或考試專業能力之機關決定**。其決定若目的正當，且其差別待遇與目的之達成間具有合理關聯，即不違反憲法第 7 條平等權保障之意旨。

釋字第 647 號理由書第 2 段

遺產及贈與稅法第二十條第一項第六款規定，配偶相互贈與之財產不計入贈與總額，乃係對有法律上婚姻關係之配偶間相互贈與，免徵贈與稅之規定，雖以法律上婚姻關係存在與否為分類標準，惟因屬免徵贈與稅之差別待遇，且考量贈與稅之課徵，**涉及國家財政資源之分配，與公共利益之維護及國家政策之推動緊密相關，立法機關就其內容之形成本即享有較大之裁量空間**，是倘系爭規定所追求之目的正當，且分類標準與差別待遇之手段與目的間具有合理關聯，即符合平等原則之要求。

（三）目的手段關聯

1. 釋字第 807 號限制女性勞工夜間工作案

理由書第 8-10 段

系爭規定之所以原則禁止雇主使女性勞工於夜間工作，其立法理由依立法過程中之討論，可知應係出於社會治安、保護母性、女性尚負生養子女之責、女性須照顧家庭及保護女性健康等考量……系爭規定之目的概為追求保護女性勞工之人身安全、免於違反生理時鐘於夜間工作以維護其身體健康，並因此使人口結構穩定及整體社會世代健康安全等，固均屬重要公共利益。

惟維護社會治安，本屬國家固有職責，且憲法增修條文第 10 條第 6 項更明定「國家應保障婦女之人身安全」。因此，**就女性夜行人身安全之疑慮，國家原即有義務積極採取各種可能之安全保護措施以為因應**，甚至包括立法課予有意使女性勞工於夜間工作之雇主必要時提供交通工具或宿舍之義務，以落實夜間工作之婦女人身安全之保障，而非採取禁止女性夜間工作之方法。乃系爭規定竟反以保護婦女人身安全為由，原則禁止雇主使女性勞工於夜間工作，**致女性原應享有並受保障之安全夜行權變相成為限制其自由選擇夜間工作之理由**，足見其手段與所欲達成之目的間顯然欠缺實質關聯。

其次，從維護身體健康之觀點，盡量避免違反生理時鐘而於夜間工作，係所有勞工之需求，不以女性為限。女性勞工於夜間工作者，亦難謂因生理結構之差異，對其身體健康所致之危害，即必然高於男性，自不得因此一律禁止雇主使女性勞工於夜間工作。至於所謂女性若於夜間工作，則其因仍須操持家務及照顧子女，必然增加身體負荷之說法，不僅**將女性在家庭生活中，拘泥於僅得扮演特定角色，加深對女性不應有之刻板印象**，更忽略教養子女或照顧家庭之責任，應由經營共同生活之全體成員依其情形合

理分擔，而非責由女性獨自承擔。況此種夜間工作與日常家務之雙重負擔，任何性別之勞工均可能有之，不限於女性勞工。又，前述說法，對單身或無家庭負擔之女性勞工，更屬毫不相關。

2. 113 年憲判字第 6 號消防警察人員類別考試身高限制案

理由第 32-34 段

惟訂製或修改符合國人身高需求之相關消防設備器材，實際上並非無從克服之困難，此由關係機關於言詞辯論時所述，目前消防設備器材已經由美規改採日規，可知消**防設備器材並非不得按照國人身高需求而為採購**。

……況且**消防工作相當多元**，包括防災宣導、備勤、消防安全檢查、支援災害現場應變、督勤（消防勤務實施要點第 11 點參照）。具體而言，除火災外，尚包括各種天然與人為災害搶救，例如地震、颱風、水災、爆炸等各種災難，甚至包括其他民眾服務案件等。身高較高之消防人員在處理某些類型之災害搶救上固然有其優勢，惟面對各種不同類型之消防勤務以及災害現場與搶救工作，身高略矮之消防人員除可以擔任一般消防勤務外，進入空間較為狹小之災害現場，亦有其優勢。凡此，均屬完整之救災團隊所不可或缺。

綜上，**關係機關僅憑其所稱之經驗及默會知識，而未能提出充足之證據資料**，說明何以系爭規定一所訂身高低於 160.0 公分之女性並不適合從事消防工作，而必須設定較男性更為嚴格之身高限制，以排除多數女性應考之原因。是系爭規定一對女性所為之不利差別待遇與所欲達成之公益目的間尚難謂具實質關聯性，其適用於消防警察人員類別之範圍內，與憲法第 7 條保障平等權之意旨不符。